חוברת 2 · מרתון

# משפט מנהלי

## מרתון למבחן

טבלאות, שרשראות פסיקה, עצי החלטה ורשימות "חייבים לזכור"

14 פרקים

הוכן ונערך ע"י

**אילן פרץ**

# תוכן העניינים

מרתון לפי פרקים


1 מבוא — מהו המשפט המנהלי ומבנה הביקורת השיפוטית

2 עקרון חוקיות המנהל וחובת הנאמנות של הרשות

3 על מי חל המשפט המנהלי — גופים ציבוריים, דו-מהותיים ודואליות נורמטיבית

4 פרשנות החוק המסמיך וכלל ההסדרים הראשוניים

5 מקורות הסמכות — סמכות שיורית, סמכות עזר, סמכות טבועה וסיווג סמכויות

6 עצמאות שיקול הדעת — הלכת מיכלין, הנחיות מנהליות ונטילת סמכות

7 התשתית העובדתית — הלכת יורונט והראיה המנהלית

8 כללי הצדק הטבעי — שימוע, ניגוד עניינים, הנמקה והיוועצות

9 פרסום תקנות והוראות מנהל ותחילת תוקף

10 שיקולים זרים, שוויון והפליה

11 עילת הסבירות

12 עילת המידתיות ומשקל ראוי לזכויות יסוד

13 עילות הסף וערכאות השיפוט — בג"ץ ובית המשפט לעניינים מנהליים

14 הבטחה מנהלית, השתק ותוצאות הפגמים — ושיטת פתרון למבחן

פרק 1

# מבוא — מהו המשפט המנהלי ומבנה הביקורת השיפוטית

## המשפט המנהלי — תמונת על

✦ **הגדרה — הגדרה** משפט מנהלי = סמכויות גופי המנהל + פרוצדורה של הפעלתן + שיקולים מהותיים + פיקוח שיפוטי.

| ארבע שאלות | מה בודקים |
|---|---|
| לאן פונים | בית משפט לעניינים מנהליים, בג"ץ, בית דין לעבודה או גוף מעין-שיפוטי |
| תנאי סף | עמידה, שפיטות, שיהוי, מעשה עשוי, מיצוי הליכים, ניקיון כפיים |
| אילו טענות | סמכות, פרוצדורה, שיקול דעת |
| איזה סעד | ביטול, החזרה, צו; פיצוי נדיר |

| קבוצה | שאלה | דוגמאות |
|---|---|---|
| סמכות | מי מוסמך | חוסר הסמכה, חריגה, אי-הפעלת שיקול דעת עצמאי |
| פרוצדורה | באיזה הליך | תשתית עובדתית, שימוע, הנמקה, פרסום, ניגוד עניינים |
| שיקול דעת | איזו מהות | שיקול זר, הפליה, סבירות, מידתיות |

| | חוקתי | מנהלי |
|---|---|---|
| מה תוקפים | חוק של הכנסת | החלטה של הרשות המבצעת |
| יחס לחוק | החוק במחלוקת | החוק נתון ומפרשים אותו |

§ **סעיף — סעיף 15(ד)(2) לחוק יסוד: השפיטה** בג"ץ נותן צווים לרשויות ולבעלי תפקידים ציבוריים; עילות ההתערבות מפותחות בפסיקה.

✔ **שורה תחתונה — שני רעיונות מסדרים** הפרדת רשויות מסדרת סמכות; חובת נאמנות מסדרת פרוצדורה ושיקול דעת.

★ **טיפ למבחן — סדר לפתרון** זיהוי ההחלטה ושרשרתה, סף, שלוש הקבוצות לפי סדר, סעד.

**! שים לב — מלכודות** לא לבלבל חוקתי ומנהלי; לא לפתוח בסבירות; לא לשכוח מעשה עשוי; פיצוי הוא חריג.

**מילות מפתח:** בית סוריק; שרשרת החלטות; שלוש קבוצות; ארבע שאלות; 15(ד)(2); חוק ההנמקות 1958; זמיר וברק-ארז.

## 1.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

## 1.2 הגדרה

✦ **הגדרה — משפט מנהלי** משפט מנהלי הוא התחום המשפטי שעוסק ב סמכויות גופי המנהל, ב פרוצדורה של הפעלת הסמכויות, ב שיקולים המהותיים של הפעלתן, וב פיקוח השיפוטי על הפעלתן התקינה.

## 1.3 פירוק ההחלטה — מה בדיוק תוקפים?

## 1.4 ארבע השאלות הבסיסיות של כל תקיפה מנהלית

| # | השאלה | מה בודקים |
|---|---|---|
| 1 | **לאן פונים?** (סמכות השיפוט) | בית המשפט לעניינים מנהליים; בג"ץ; בית הדין לעבודה (למשל בהחלטות ביטוח לאומי); או גוף מעין-שיפוטי — כמו ועדת ערר לתכנון ובנייה (פרק 13) |
| 2 | **האם עומדים בתנאי הסף?** | "עילות הסף": זכות עמידה, שפיטות, שיהוי (בדרך כלל 45 ימים — "התיישנות" קצרה של המשפט המנהלי), מעשה עשוי, מיצוי הליכים, ניקיון כפיים, עתירה תיאורטית (פרק 13) |
| 3 | **אילו טענות אפשר לטעון?** (העילות המהותיות) | שלוש קבוצות — ראו להלן. בניגוד למשפט האזרחי, כאן אפשר לטעון, למשל, שהחלטה **אינה סבירה** |
| 4 | **איזה סעד?** (תוצאות הפגמים) | ביטול ההחלטה, החזרה לדיון מחדש, צו עשה או צו מניעה. בית המשפט המנהלי כמעט אף פעם אינו פוסק פיצויים (פרק 14) |

## 1.5 לב הקורס — שלוש קבוצות של טענות מהותיות

| קבוצה | השאלה | דוגמאות | פרקים |
|---|---|---|---|
| **1. סמכות** | האם הגורם שהחליט מוסמך לכך? | אין הסמכה בחוק; הסמכה כללית מדי לפגיעה בזכויות; חריגה מגבולות ההסמכה; אי-הפעלת שיקול דעת עצמאי | 2–6 |
| **2. פרוצדורה** | האם ההחלטה התקבלה בתהליך הנכון? | העדר תשתית עובדתית; אי-מתן זכות טיעון ועיון (שימוע); העדר הנמקה; פגם בפרסום; ניגוד עניינים, משוא פנים ודעה קדומה | 7–9 |
| **3. שיקול דעת** (מהות) | גם אם הייתה סמכות והפרוצדורה תקינה — האם ההחלטה עצמה פגומה? | שיקולים זרים; הפליה; חוסר סבירות; חוסר מידתיות; אי-מתן משקל ראוי לזכויות יסוד | 10–12 |

★ **טיפ למבחן — מה לעשות במבחן** בכל תרחיש עובדתי — עברו על שלוש הקבוצות לפי הסדר. כך לא תחמיצו טענה.

## 1.6 דוגמה מלאה — בית סוריק (בג"ץ 2056/04)

## 1.7 משפט מנהלי ומשפט חוקתי

| | משפט חוקתי | משפט מנהלי |
|---|---|---|
| עניינו | (1) היחסים בין שלוש הרשויות; (2) זכויות היסוד והגנתן החוקתית | היחסים בין האזרח לבין **הרשות המבצעת** |
| מה תוקפים | **חוק** של הכנסת — בטענה שהוא סותר חוק יסוד ואינו עומד בפסקת ההגבלה (ולעיתים — פגמים בהליך החקיקה) | **החלטה** של הרשות המבצעת: תקנות, הנחיות, החלטות פרטניות |
| יחס לחוק | החוק עצמו במחלוקת | החוק **נתון**; אפשר רק לפרש אותו |
| היקף | רחב בנושאים, מעט מקרים | צר בנושא, אינספור מקרים |

## 1.8 המקורות הפורמליים — רוב המשפט המנהלי הוא פסיקה

§ **סעיף — 15(ד)(2) לחוק יסוד: השפיטה** — בג"ץ מוסמך "לתת צווים לרשויות המדינה, לרשויות מקומיות, לפקידיהן ולגופים ולאנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין, לעשות מעשה או להימנע מעשות מעשה במילוי תפקידיהם כדין, ואם נבחרו או נתמנו שלא כדין — להימנע מלפעול".

## 1.9 המקורות המהותיים — שני רעיונות מסדרים

| רעיון | מה הוא מסדר |
|---|---|
| **הפרדת הרשויות** | את דרישת ה**סמכות**: הרשות המבצעת פועלת רק במסגרת מה שהמחוקקת הסמיכה, והשופטת מוודאת שלא חרגה (פרק 2) |
| **חובת הנאמנות של עובד הציבור** | את דרישות ה**פרוצדורה** וה**שיקול הדעת**: עובד הציבור הוא נאמן שמנהל את נכסי הציבור, ולכן חייב לאסוף נתונים, לשמוע, לנמק, להימנע מניגוד עניינים ומשיקולים זרים, לפעול בסבירות ובמידתיות (פרק 2) |

## 1.10 מלכודות נפוצות

**! שים לב — מלכודות נפוצות** לבלבל בין תקיפת חוק (חוקתי) לתקיפת החלטה (מנהלי). לחשוב שיש חוק כללי שקובע את עילות ההתערבות — רובן נקבעו בפסיקה.

## 1.11 שלד לפתרון שאלה — מהלך קבוע בארבעה צעדים

★ **טיפ למבחן — סדר הכתיבה בבחינה** פתחו בשורה אחת שמסווגת את הטענה ("זו טענת סמכות"), ורק אחר כך פרטו. בודק שרואה סיווג נכון מיד מבין שהסדר בראשכם.

## 1.12 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

| הטעות | למה היא שגויה | התיקון |
|---|---|---|
| לפתוח בסבירות | סבירות היא כלי אחרון; ייתכן שההחלטה פגומה כבר בסמכות או בפרוצדורה | לבדוק קודם סמכות ופרוצדורה |
| לערבב חוקתי ומנהלי | תקיפת לשון החוק היא חוקתית; תקיפת החלטה היא מנהלית | לשאול: מה נתקף – החוק או ההחלטה? |
| להתעלם משרשרת ההחלטות | פגם בתקנה או בהנחיה יכול להפיל החלטה שנראית תקינה | לעקוב אחורה עד לחוק המסמיך |
| לשכוח עילות סף | עתירה מצוינת עלולה להידחות בשל שיהוי או מעשה עשוי | לבדוק תנאי סף לפני המהות |
| לבקש פיצויים בעתירה | הסעד הרגיל הוא ביטול או צו; פיצויים הם חריג נדיר | לבקש צו או ביטול, ולבחון הליך נפרד לפיצוי |

## 1.13 תרגיל פתור — מכתב אחד ושתי החלטות

## 1.14 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** המשפט המנהלי הוא דיני ההחלטה של הרשות המבצעת: סמכות, פרוצדורה, שיקול דעת, ופיקוח שיפוטי. ארבע שאלות בכל תקיפה: לאן פונים, האם עומדים בסף, אילו טענות, איזה סעד.

## 1.15 מילון מושגים

## 1.16 נקודות מפתח למבחן

✔ **שורה תחתונה — עיקרי הפרק** הגדרה: סמכויות, פרוצדורה, שיקולים מהותיים ופיקוח שיפוטי על גופי המנהל. ארבע שאלות: לאן פונים; תנאי סף; אילו טענות; איזה סעד.

## 1.17 שאלות בסגנון המבחן

## 1.18 שאלות לחשיבה

## שרשרת פסיקה בפרק

| פסק דין | ההלכה |
|---|---|
| **בג"ץ 2056/04 מועצת הכפר בית סוריק נ' ממשלת ישראל** | הלכה: העתירה התקבלה בחלקה. הטענות סודרו בשלוש קבוצות: סמכות (צווי התפיסה), פרוצדורה (העדר פרסום וארכה קצרה מדי, ולכן העדר זכות טיעון) ושיקול דעת (פגיעה לא מידתית בקניין, בתנועה ובפרנסה). בית המשפט החליט בעיקר מטעמי מידתיות. חשיבות למבחן: הדוגמה הקלאסית למבנה תקיפה מנהלית מלא, וניתן לאמץ אותה כשלד לתשובה. |

| | |
|---|---|
| **סעיף 15(ד)(2) לחוק יסוד: השפיטה (הוראת חוק)** | תוכן: הסעיף מגדיר על מי חל הפיקוח ומקנה לבג"ץ סמכות לתת צווים. הוא אינו קובע מתי מתערבים, ואת העילות פיתחה הפסיקה. חשיבות למבחן: הבסיס הנורמטיבי לבג"ץ, ונקודת מוצא לשאלה על מי חל המשפט המנהלי (פרק 3). |
| **חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), התשי"ט–1958 (הוראת חוק)** | תוכן: מחייב עובד ציבור לנמק החלטות בנסיבות שנקבעו בחוק (פרק 8). חשיבות למבחן: מדגים שרוב המשפט המנהלי הוא פסיקה ורק חלקו הוסדר בחוקים ספציפיים, ויחד איתו חוק חופש המידע שמעניק זכות עיון. |

פרק 2

# עקרון חוקיות המנהל וחובת הנאמנות של הרשות

## חוקיות המנהל וחובת הנאמנות

✦ **הגדרה — חוקיות המנהל** רשות ציבורית רשאית לעשות רק מה שהחוק (או תקנה מכוחו) הסמיך אותה. לפרט מותר כל מה שלא נאסר.

| דרישה | על מי חלה |
|---|---|
| התאמה לחוק | על כולם, גם על המדינה |
| הסמכה בחוק | רק על גופים ציבוריים |

| פסק דין | ההלכה |
|---|---|
| בז'רנו | פגיעה בעיסוק דורשת הסמכה מפורשת; על הפקיד להוכיח צידוק; פרשנות מצמצמת פגיעה |
| שייב | אפילו שר הביטחון נדרש להסמכה |
| ירדור / ניימן | דמוקרטיה מתגוננת – חריג; ניימן צמצם; החוק תוקן |
| פרחי ביקל | כתב שיפוי ללא הסמכה – חריגה מדל"ת אמות הסמכות |
| 158/21 | הנחיה בחוסר סמכות – בטלה |

✔ **שורה תחתונה — בעיית הנציג** כוח בנכסי הזולת + פער מידע + ניגוד אינטרסים. הפתרון: חובת אמון – לפעול לטובת המיוצג בלבד, ואיסור על ניגוד עניינים, גם חשש.

| פסק דין | נגזר מנאמנות |
|---|---|
| פרץ | שוויון |
| שפירא | הגינות; הנכסים מופקדים בנאמנות |
| מרכז הקבלנים | סבירות, יושר, תום לב, אי-הפליה |

| קונטרם – שופט | עמדה |
|---|---|
| זמיר | חובת הגינות כללית של הפרט |
| ברק | חובת גילוי כשהמידע בידי הפרט |
| חשין | רק אם נקבע בחוק |

★ **טיפ למבחן — לבחינה** סמכות קודם. מצאתם הסמכה? עברו לנאמנות. ובדקו גם את הגינות העותר.

! **שים לב — מלכודות** אין לומר "מותר כל מה שלא נאסר" על רשות; ירדור אינו כלל; בעבאדה פעולה בלי סמכות אינה יוצרת זכות.

**מילות מפתח:** דל"ת אמות הסמכות; האל"ף-בי"ת; בעיית הנציג; יחס שווה אל שווים; דואליות (טבריה); רשות מאזנת (בוצר).

## 2.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

## 2.2 שלטון החוק — שתי דרישות

| דרישה | על מי חלה | תוכן |
|---|---|---|
| **שלטון החוק הכללי** (עקרון ההתאמה לחוק) | על כולם — גם על המדינה | גם המדינה, כמו כל אדם, חייבת לפעול לפי החוק ולא בניגוד לו |
| **דרישת ההסמכה בחוק** (חוקיות המנהל) | רק על גופים ציבוריים | גוף ציבורי אינו רשאי לבצע **שום** פעולה, אלא אם יש לו סמכות בחוק לעשותה |

## 2.3 בז'רנו — פסק הדין המכונן (בג"ץ 1/49)

## 2.4 שייב — גם מול ראש הממשלה (בג"ץ 144/50)

## 2.5 החריג — ירדור (ע"ב 1/65), וגבולותיו — ניימן (ע"ב 2/84)

## 2.6 העיקרון היום

## 2.7 חובת הנאמנות — "בעיית הנציג"

## 2.8 חובת הנאמנות בפסיקה

## 2.9 הצד השני — חובת ההגינות של הפרט כלפי הרשות

| שופט | העמדה |
|---|---|
| **זמיר** | הרשות, כנאמן, חייבת בהגינות — וחובה זו חלה כלפי כל אדם. וגם **הפרט חייב בהגינות כלפי השלטון**, מתוך תפיסה של שיתוף פעולה — חובה כללית |
| **ברק** | אין חובה כללית כזו בחוק; אבל **חובת הגילוי** נגזרת מהצורך של הרשות לבסס **תשתית עובדתית** ראויה, כשהמידע מצוי בידי הפרט |
| **חשין** | חובת הגינות של הפרט כלפי הרשות אינה קיימת, אלא אם נקבעה במפורש בחוק |

## 2.10 כשהנאמן "נאמן לעצמו"

## 2.11 מלכודות נפוצות

**! שים לב — מלכודות נפוצות** לחשוב שעקרון החוקיות קבוע בחוק — הוא פרי הפסיקה. לחשוב שלרשות "מותר כל מה שאינו אסור" — זה כלל הפרט.

## 2.12 שלד לפתרון שאלה — חוקיות המנהל ונאמנות

## 2.13 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

| הטעות | למה היא שגויה | התיקון |
|---|---|---|
| "לרשות מותר מה שלא נאסר" | זה כלל הפרט. לרשות מותר רק מה שהוסמכה לעשות | לחפש הסמכה בחוק |
| לחשוב שגורם בכיר מוסמך מעצם בכירותו | שייב: גם שר הביטחון וראש הממשלה זקוקים להסמכה בחוק | לבדוק את מקור הסמכות של הגורם הספציפי |
| לראות בירדור כלל כללי | ירדור חריג מצומצם לנסיבותיו; ניימן קבע שלא חוזרים עליו | להזכיר ירדור רק כחריג וגבולותיו |
| לחשוב שחובות ההגינות חלות רק עלקונטרם: גם הפרט חייב בהגינות ובגילוי הרשות | מידע מהותי | לבחון את התנהגות העותר |

להסיק שרשות במישור החוזי פטורה ממשפט מנהלי  אברהם נ' עיריית טבריה: חלות עליה חובות להחיל דואליות נורמטיבית מנהליות גם בחוזה

## 2.14 תרגיל פתור — מאגר החניה של העירייה

## 2.15 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** חוקיות המנהל: רשות רשאית לעשות רק מה שהחוק הסמיך אותה; הפרט רשאי הכל פרט למה שנאסר. שני מרכיבים בשלטון החוק:

## 2.16 מילון מושגים

## 2.17 נקודות מפתח למבחן

✔ **שורה תחתונה — עיקרי הפרק** שתי דרישות: התאמה לחוק (כולם) והסמכה בחוק (רשויות). בז'רנו: הסמכה מפורשת לפגיעה בחופש העיסוק; לפרש סמכות כך שתימנע פגיעה; "על הפקיד להוכיח צידוק".

## 2.18 שאלות בסגנון המבחן

## 2.19 שאלות לחשיבה

## שרשרת פסיקה בפרק

| פסק דין | ההלכה |
|---|---|
| **בג"ץ 1/49 בז'רנו נ' שר המשטרה** | הלכה: העתירה התקבלה. לרשות מותר לעשות רק מה שהחוק הסמיך אותה, ופגיעה בחופש העיסוק מחייבת הסמכה מפורשת. גם רשות מוסמכת צריכה לפרש את סמכותה כך שתימנע פגיעה בזכויות, ועל הפקיד להוכיח צידוק לאיסור. חשיבות למבחן: פסק הדין המכונן של חוקיות המנהל, ונקודת מוצא לכל שאלת סמכות. |

**בג"ץ 144/50 שייב נ' שר הביטחון** הלכה: העתירה התקבלה. לשר הביטחון אין סמכות להורות בעניין העסקת מורים, ולכן ההחלטה בטלה מכל טעם. דרישת הסמכות חלה גם על הדרג הבכיר ביותר, ובית המשפט לא נרתע מלהכריע נגדו. חשיבות למבחן: חוקיות המנהל מול בעל סמכות בכיר, ובנוסף עצמאות שיקול הדעת (פרק 6).

**ע"ב 1/65 ירדור נ' ועדת הבחירות; ע"ב 2/84 ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות** הלכה: בירדור אושרה הפסילה, בנימוק של "דמוקרטיה מתגוננת" – חריג שבו עקרונות יסוד של השיטה גוברים על חוקיות המנהל. בניימן נקבע שאין סמכות לפסול את הרשימות, שירדור צומצמה לנסיבותיה, ולאחר מכן תוקן החוק. חשיבות למבחן: החריג הנדיר וגבולותיו.

**בג"ץ 158/21 רופאים לזכויות אדם נ' השר לביטחון פנים** הלכה: ההנחיה ניתנה בחוסר סמכות מובהק ובניגוד לדין, וממילא נעדרת תוקף משפטי; הסמכות לפי פקודת בריאות העם נתונה לגורם אחר. חשיבות למבחן: יישום עכשווי של חוקיות המנהל כשגורם מבצעי נוטל סמכות שאינה שלו.

**בג"ץ 262/62 פרץ נ' המועצה המקומית כפר שמריהו** הלכה: העתירה התקבלה. הרשות נטלה על עצמה תפקיד של נאמן כלפי הציבור והיא חייבת להתייחס יחס שווה אל שווים. חשיבות למבחן: מקור עקרון השוויון, ופסק הדין הראשון המדגים את חובת הנאמנות.

**בג"ץ 164/97 קונטרם נ' משרד האוצר – אגף המכס** הלכה: העתירה נדחתה. זמיר: חובת הגינות כללית של הפרט כלפי הרשות. ברק: חובת גילוי הנגזרת מצורך הרשות בתשתית עובדתית כשהמידע בידי הפרט. חשין: רק אם נקבע בחוק. מכל העמדות עולה שהפרט חייב לגלות מידע מהותי. חשיבות למבחן: הצד השני של הנאמנות, ושלוש העמדות.

**בג"ץ 7081/93 בוצר נ' המועצה המקומית מכבים-רעות** הלכה: הרשות חייבת לאזן בין שיקולי תקציב לבין זכויות, ואינה יכולה להסתתר מאחורי הבירוקרטיה; היא חויבה לפעול. חשיבות למבחן: רשות מאזנת כנאמן, וקשר בין נאמנות לזכויות יסוד.

פרק 3

# על מי חל המשפט המנהלי — גופים ציבוריים, דו-מהותיים ודואליות נורמטיבית

## על מי חל המשפט המנהלי

§ **סעיף — סעיף 15(ד)(2) לחוק יסוד: השפיטה** רשויות מדינה, רשויות מקומיות, פקידיהן, וגופים ואנשים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין.

| סוג הגוף | מעמד |
|---|---|
| משרד ממשלתי, רשות מקומית | ציבורי מלא |
| תאגיד סטטוטורי (בנק ישראל, ביטוח לאומי) | ציבורי, אישיות נפרדת, עצמאות |
| חברה ממשלתית | לרוב דו-מהותית |
| גוף פרטי | משפט פרטי; דו-מהותי רק אם מתקיימים מבחנים; תחולה עקיפה |

✦ **הגדרה — דואליות נורמטיבית** נורמות פרטיות וציבוריות חלות במקביל על אותו גוף.

| פסק דין | ההלכה |
|---|---|
| מיקרודף | "יצור כלאיים"; מהות ולא צורה; ארבעה סממנים; עקרונות יסוד |
| קסטנבאום | דו-מהותיות או תחולה עקיפה (ברק) |
| שטרית | די בשירות חיוני; ועדת חריגים כגוף מעין-שיפוטי |
| אברמוביץ | בעלות + תפקיד ציבורי; גם חריגה מסמכות |
| און | דו-מהותיות חלקית; חמישה שיקולים (זמיר) |
| נעאמנה / פרומר | תום לב ותקנת הציבור |

✔ **שורה תחתונה — שני מבחנים חלופיים** (1) שירות חיוני; (2) בעלות מדינה או רשות מקומית + תפקיד ציבורי.

| חמשת שיקולי און |
|---|
| סמכות שלטונית |
| אמצעי חיוני |

מונופול
תמיכה שלטונית
תפקיד ציבורי

★ **טיפ למבחן — לבחינה** כשהגוף פרטי: דו-מהותיות, תחולה עקיפה, חוק ההפליה (2000) – שלושה מסלולים.

! **שים לב — מלכודות** סבירות מנהלית אינה חלה על גוף פרטי; סיווג לפי פעילות; חוק ההפליה אינו מחייב דו-מהותיות.

**מילות מפתח:** יצור כלאיים; מהות לא צורה; שירות חיוני; מקום ציבורי; תקנת הציבור; תום לב.

## 3.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

## 3.2 הגופים של המשפט הציבורי — סעיף 15(ד)(2) לחוק יסוד: השפיטה

| קבוצה | דוגמאות | הערות |
|---|---|---|
| **רשויות המדינה ופקידיהן** | משרדי הממשלה, צבא, משטרה, שב"ס | כולל את **הכנסת** ו**הנהלת בתי המשפט** כשהן פועלות כמעסיק או כמנהל — למשל מנכ"ל הכנסת שמפטר עובד |
| **רשויות מקומיות ופקידיהן** | עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות | |
| **גופים ואנשים הממלאים תפקיד ציבורי על פי דין** | תאגידים סטטוטוריים: בנק ישראל, המוסד לביטוח לאומי, רשות שדות התעופה; וגם יחידים: יו"ר ועדת חקירה ממלכתית, חבר ועדה לתכנון ובנייה | המחוקק הקים אותם **בחוק** — אבל רשות שדות התעופה; וגם יחידים: יו"ר ועדת במכוון **לא כחלק מהמדינה** |

## 3.3 דואליות נורמטיבית

| סוג הגוף | טענות פרטיות | טענות ציבוריות |
|---|---|---|
| גוף ציבורי | ✓ (למשל בחוזה) | ✓ |
| גוף פרטי | ✓ | ✗ |
| גוף דו-מהותי | ✓ | ✓ — **חלק** מהכללים |

## 3.4 חברות ממשלתיות

## 3.5 נקודת המוצא — מיקרודף נ' חברת החשמל (בג"ץ 731/86)

## 3.6 חברה קדישא נ' קסטנבאום (ע"א 294/91)

| שופט | הדרך | המבחן |
|---|---|---|
| **שמגר** | זו שאלה ציבורית: חברה קדישא היא גוף דו-מהותי, וחייבת לכבד את **כבוד האדם** — כוללשירות מהותי האוטונומיה להחליט איך להתאבל ולהנציח | + מונופול |
| **אלון** | מסכים עקרונית שהיא דו-מהותית; אבל לדעתו חיוב כיתוב עברי אינו פוגע בכבוד האדם (דעת מיעוט בתוצאה) | עצם השירות החיוני |
| **ברק** | המבחן המחמיר: שלושה סממנים — תפקיד חיוני, מונופול, סמכויות מעין-שלטוניות (גביית אגרות קבורה לפי קביעת משרד הדתות). ו**דרך חלופית**: **תחולה עקיפה** של זכויות סממנים היסוד דרך **מושגי השסתום** של המשפט הפרטי — תום לב, תקנת הציבור, תנאי מקפח. סעיף הפוגע בכבוד האדם — נוגד את תקנת הציבור; התנהגות מפלה — חוסר תום לב | שלושה |

## 3.7 שלושה מסלולים שהתפתחו

| מסלול | תוכן | דוגמאות |
|---|---|---|
| **1. הכרה בגופים דו-מהותיים** | הרחבת הקטגוריה והחלת כללים ציבוריים | שטרית, אברמוביץ, און, חלמיש |
| **2. תחולה עקיפה של זכויות יסוד** | פרשנות מושגי השסתום במשפט הפרטי לאור זכויות היסוד | נעאמנה, פרומר |
| **3. חקיקה** | הסדרה ישירה של איסור ההפליה | חוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים (2000) |

## 3.8 מסלול 1 — שלוש שאלות על גופים דו-מהותיים

✦ **הגדרה — המבחנים היום — שני מבחנים חלופיים** (1) האם הגוף מספק שירות חיוני ; או (2) האם הוא בבעלות המדינה או רשות מקומית וממלא תפקיד ציבורי חשוב.

## 3.9 מסלול 2 — תחולה עקיפה

## 3.10 מסלול 3 — חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000

## 3.11 מלכודות נפוצות

**! שים לב — מלכודות נפוצות** לחשוב שחברה ממשלתית היא גוף ציבורי לכל דבר — היא במהותה פרטית, ולרוב דו-מהותית. לחשוב שעל גוף דו-מהותי חלים כל כללי המשפט המנהלי — "לא בהכרח למכלול".

## 3.12 שלד לפתרון שאלה — האם הגוף כפוף למשפט המנהלי?

## 3.13 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

| הטעות | למה היא שגויה | התיקון |
|---|---|---|
| "כל חברה ממשלתית היא גוף ציבורי מלא" | חברה ממשלתית היא לרוב דו-מהותית; הכללים תלויים בתפקיד ובפעילות | לבחון את מהות התפקיד |
| לדרוש את כל ארבעת הסממנים של מיקרודף | בשטרית נקבע שדי בשירות חיוני כסממן אחד | להזכיר את שני המבחנים החלופיים |
| להחיל סבירות מנהלית על גוף פרטי | גוף פרטי נבחן במשפט הפרטי; סבירות מנהלית אינה חלה | לנסות תחולה עקיפה (תקנת הציבור, תום לב) |
| לסווג גוף כציבורי "כולו" או פרטי "כולו" | באון ובכללית נקבעה דו-מהותיות חלקית – לפי הפעילות | לבחון את הפעילות הספציפית |
| לשכוח את החקיקה | חוק ההפליה (2000) חל על מקומות ושירותים ציבוריים גם בלי קביעת דו-מהותיות | לבדוק חוק ספציפי לפני הלכות |

## 3.14 תרגיל פתור — מרכז קניות פרטי

## 3.15 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** סעיף 15(ד)(2): הגופים הכפופים כוללים רשויות מדינה, רשויות מקומיות, פקידיהן וגופים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין. תאגיד סטטוטורי (בנק ישראל, ביטוח לאומי) הוא גוף ציבורי; חברה ממשלתית היא לרוב דו-מהותית.

## 3.16 מילון מושגים

## 3.17 נקודות מפתח למבחן

✔ **שורה תחתונה — עיקרי הפרק** ס' 15(ד)(2): רשויות המדינה, רשויות מקומיות, גופים הממלאים תפקיד ציבורי על פי דין. מיקרודף: "יצור כלאיים"; מהות התפקיד, לא הצורה; ארבעה סממנים; עקרונות היסוד חלים.

## 3.18 שאלות בסגנון המבחן

## 3.19 שאלות לחשיבה

## שרשרת פסיקה בפרק

| פסק דין | ההלכה |
|---|---|
| **בג"ץ 731/86 מיקרודף נ' חברת החשמל** | הלכה: ברק קבע שחברת החשמל היא "יצור כלאיים" – גוף דו-מהותי. לא הצורה הארגונית קובעת אלא מהות התפקיד: בעלות מדינה, שירות חיוני, מונופול וסמכויות מעין-שלטוניות. עליה חלים עקרונות היסוד של המשפט הציבורי – הגינות, שוויון, סבירות ותום לב – אך לא בהכרח כל כללי המשפט המנהלי. חשיבות למבחן: נקודת המוצא של תורת הדו-מהותיות. |
| **ע"א 294/91 חברה קדישא גחש"א נ' קסטנבאום** | הלכה: הערעור נדחה. שמגר ואלון ראו בחברה גוף דו-מהותי שחל עליו עקרון כבוד האדם; ברק זיהה שלושה סממנים ופתח דרך חלופית של תחולה עקיפה של זכויות יסוד דרך תקנת הציבור ותום הלב. חשיבות למבחן: שני המסלולים לשמירה על זכויות במגזר הפרטי. |

| | |
|---|---|
| **ע"ע 1091/00 שטרית נ' קופת חולים מאוחדת** | הלכה: די בסממן אחד – מתן שירות חיוני – כדי להגדיר גוף דו-מהותי. ועדת החריגים נחשבת גוף מעין-שיפוטי וחלות עליה חובות: פרוטוקול, זכות טיעון, זכות עיון, החלטה מנומקת, סבירות והגינות. חשיבות למבחן: הרחבת ההגדרה והחלת כללים פרוצדורליים. |
| **בג"ץ 4289/00 אברמוביץ נ' ראש הממשלה והחברה לפיתוח הרובע היהודי** | הלכה: החברה נחשבה דו-מהותית בשל בעלות ממשלתית ותפקיד ציבורי. השופטים בחנו גם חריגה מסמכות וגם סבירות, והרוב דחה את העתירה. חשיבות למבחן: מבחן חלופי שני לדו-מהותיות, והחלת עקרון הסמכות על גוף דו-מהותי. |
| **ע"א 3414/93 און נ' מפעלי בורסת היהלומים** | הלכה: השופט זמיר קבע שההבחנה בין קניין פרטי לציבורי אינה חדה (כמו קניון או אצטדיון), וגוף פרטי יכול להיות דו-מהותי בחלק מפעילותו. חמישה שיקולים: סמכות שלטונית, אמצעי חיוני, מונופול, תמיכה שלטונית ותפקיד ציבורי. התיק הוחזר לבירור. חשיבות למבחן: דו-מהותיות חלקית. |
| **ת"א 11259/93 נעאמנה נ' קיבוץ קליה; ע"ע 164/99 פרומר נ' רדגארד** | הלכה: בנעאמנה הפליה נחשבה לחוסר תום לב בקיום חוזה. בפרומר, פגיעה בלתי סבירה ובלתי מידתית בחופש העיסוק נוגדת את תקנת הציבור ובטלה. חשיבות למבחן: מסלול התחולה העקיפה על גוף פרטי. |
| **חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000 (הוראת חוק)** | תוכן: החוק מגדיר מקום ציבורי ושירות ציבורי, אוסר הפליה ומאפשר פיצוי ללא הוכחת נזק, בלי צורך לקבוע דו-מהותיות. חשיבות למבחן: המסלול השלישי לצד דו-מהותיות ותחולה עקיפה. |

פרק 4

# פרשנות החוק המסמיך וכלל ההסדרים הראשוניים

## פרשנות ההסמכה והסדרים ראשוניים

§ **סעיף — חוק הפרשנות** ס' 11 – זמן סביר; ס' 15 – ביטול תקנה באותה דרך; ס' 17(ב) – סמכויות עזר במידה המתקבלת על הדעת; ס' 20 – רוב.

✦ **הגדרה — כלל פרשנות 1** ככל שהפגיעה בזכויות יסוד חמורה יותר – נדרשת הסמכה ברורה, מפורטת ומפורשת. ולהפך: בלי פגיעה – פרשנות רחבה.

| פסק דין | ההלכה |
|---|---|
| קטלן | חוקן – נדרשת הסמכה מפורשת; חוקק חוק 1996 |
| מאנע | "להיכנס לחצר" – אין עיקול במחסומים |
| פלונית | מעקבים – פגיעה בפרטיות, הסמכה מפורטת |
| החתול | אין פגיעה בזכויות – פרשנות רחבה ("מטרד") |

✦ **הגדרה — כלל פרשנות 2** הסדרים ראשוניים (מדיניות כללית ואמות מידה עקרוניות) בחקיקה ראשית; משניים – בתקנות.

| פסק דין | ההלכה |
|---|---|
| שנסי | ההסמכה הגורפת "טופחת על פני שלטון החוק" |
| רובינשטיין | כלל פרשני (ברק); "או מטעמים אחרים" מצומצם; חשין – שוויון; חוק טל |
| ועדת המעקב | אזורי עדיפות = הסדר ראשוני; ס' 32 לא מספיק |
| 616/11 | חוקתי (רובינשטיין) |
| יצוא גז | "צריך עיון"; ללא פגיעה ממשית – די בהסמכה משתמעת |

✔ **שורה תחתונה — הכלל המאוחד** ככל שהסמכות פוגעת יותר בזכויות או מסדירה נושא בעל משמעות חברתית גדולה – נדרשת הסמכה מפורשת עם הסדרים ראשוניים.

★ **טיפ למבחן — לבחינה** שני כללים: עוצמת הפגיעה; משמעות הנושא. ציינו את המחלוקת על מעמד הכלל.

! **שים לב — מלכודות** הסמכה כללית אינה תמיד מספיקה; תקנות שעת חירום יפורשו בצמצום; בחתול הפרשנות רחבה.

**מילות מפתח:** דווקנית; הסדר ראשוני; חקיקה ראשית; סמכויות עזר; הסמכה משתמעת; צריך עיון; תקנות שעת חירום (ס' 39).

## 4.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

## 4.2 מקור הסמכות — רק בחקיקה ראשית

## 4.3 חוק הפרשנות, התשמ"א–1981 — פרק ג': פירוש הסמכות

| סעיף | הכלל | דוגמה / משמעות |
|---|---|---|
| 11 | הסמכה או חובה **בלי קביעת זמן** — לעשות "**במהירות הראויה**" ולחזור ולעשות "ככל הנדרש" | אם המנהל לא קבע כללים שלושה חודשים — סביר; עשר שנים — אפשר לעתור ולדרוש |
| 12 | הסמכה ליתן פטור או הקלה — כוללת לתת אותם **במקצת או בתנאים** | |
| 13 | מינוי בשם האדם או בשם המשרה; מינוי בשם המשרה — חל על מי שממלא אותה מזמן לזמן | |
| 14 | הסמכה **למנות** — כוללת להתלות, לבטל, לפטר ולהשעות | |
| 15 | הסמכה להתקין תקנות או ליתן הוראת מינהל — כוללת לתקן, לשנות, להתלות ולבטל — **בדרך שבה הותקנו** | אם מינוי היועמ"ש נעשה אחרי ועדת איתור — גם פיטוריו מחייבים אותו הליך (פרק 8) |
| 16 | הסמכה למנות גוף — כוללת למנות יו"ר וממלאי מקום | |
| 17(א) | הסמכה לעשות או להכריע — כוללת לקבוע **נוהל עבודה וסדרי דיון** | |
| 17(ב) | הסמכה לעשות דבר — כוללת **"סמכויות עזר** הדרושות לכך במידה המתקבלת על הדעת" | הפעלת נמל תעופה כוללת שכירת עובדים ויועצים — חריג לחוקיות המנהל (פרק 5) |
| 18 | סמכות בערר — לאשר, לשנות, לבטל, להחליט אחרת או להחזיר | |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | סמכות לפי חיקוק אחד אינה גורעת מסמכות לפי חיקוק אחר | ריבוי מקורות סמכות (פרק 5) |
| 20 | פעולה שהוטלה על מספר בני אדם — כשרה אם נעשתה בידי **רובם** | |

## 4.4 כלל פרשנות מס' 1 — עוצמת הפגיעה קובעת את רמת ההסמכה

§ **סעיף — ציטוט / הסעיף** "כשפעולתה של הרשות עלולה להביא לפגיעה בזכות יסוד מוכרת, מקבלת ההקפדה על עיקרון [חוקיות המנהל] משנה חשיבות... אין הרשות יוצאת ידי חובתה בהצבעה על הוראת חוק כללית שיכולה להתפרש כמקור הסמכה לפעולתה...

✦ **הגדרה — כלל פרשנות מס' 1** ככל שהסמכות המבוקשת פוגעת יותר בזכויות יסוד — הפרשנות דווקנית, ונדרשת הסמכה ברורה, מפורטת ומפורשת . ככל שאינה פוגעת בזכויות יסוד — הפרשנות רחבה, ודי בהסמכה כללית.

## 4.5 כלל פרשנות מס' 2 — הסדרים ראשוניים בחקיקה ראשית

| סוג ההסמכה | דוגמה | שיקול הדעת שנותר |
|---|---|---|
| **רחבה וכללית** | "ראש מינהל התעופה יקבע את הכללים בנוגע לרישוי והפעלה של כלי טיס" | כמעט בלתי מוגבל |
| **עם הסדרים ראשוניים** | "לא יפעיל אדם כלי טיס אלא ברישיון. לשם כך: מעל גיל 21; מינימום שעות משמעותי, אבל מתוחם במסגרת טיסה *כפי שיקבע* הראש; מבחן עיוני ומעשי *בנושאים שיקבע*; בדיקות בריאות *שיקבע בהתייעצות* עם מנכ"ל משרד הבריאות" | |
| **עם הסדרים ראשוניים ומשניים** | כנ"ל, אבל עם 50 שעות, נושאי המבחן ותחומי הבדיקות — במפורש | בעיקר ביצוע |

★ **טיפ למבחן — מה לעשות במבחן** כשהמחוקק "מרבה במלל" — אם המלל מגביל או קובע קטגוריות, יש הסדרים ראשוניים; אם המלל רק מרחיב את הסמכות — זו עדיין הסמכה כללית.

## 4.6 שנסי נ' המפקח על היהלומים (בג"ץ 2740/96)

## 4.7 רובינשטיין נ' שר הביטחון (בג"ץ 3267/97)

## 4.8 התלכדות שני הכללים — ועדת המעקב העליונה (בג"ץ 11163/03)

✦ **הגדרה — הכלל המאוחד** ככל שהסמכות המבוקשת פוגעת יותר בזכויות יסוד, או מבקשת להסדיר נושא בעל משמעות חברתית גדולה ("בעיה לאומית") — הפרשנות דווקנית, וההסמכה צריכה להיות ברורה, מפורטת ומפורשת ולכלול הסדרים ראשוניים.

## 4.9 חוקתי או פרשני? — השאלה הפתוחה

| פסק הדין | העובדות | העמדה |
|---|---|---|
| **התאחדות הסטודנטים וחדו"ש נ' הממשלה (בג"ץ 616/11)** | מלגות לאברכי כולל נקבעו בשורה בחוק התקציב ("מלגת לימוד... 100 מיליון ₪ בשנה"), והקריטריונים — בהחלטת ממשלה | השופט **רובינשטיין**: הסדר ראשוני חסר — נוגד את חובת השוויון, והסעיף **בטל**: יש לראות בכלל **כלל חוקתי** (פגיעה בזכות רק "בחוק או לפי חוק... מכוח הסמכה מפורשת בו") |
| **המרכז האקדמי למשפט ועסקים נ' ממשלת ישראל (בג"ץ 4491/13)** | מדיניות יצוא הגז הטבעי (בעקבות ועדת צמח), מכוח סעיפים כללי בחוק הנפט | **הרוב** (גרוניס ואחרים): אף שזה הסדר ראשוני — החזקה **ניתנת לסתירה**; כשאין פגיעה ממשית בזכויות, די ב**הסמכה משתמעת**. המעמד — **"צריך עיון"**; עמדת רובינשטיין אינה מחייבת. **המיעוט** (ג'ובראן): יש להתמקד בחשיבות ההחלטה, ולא רק בפגיעה בזכויות |
| **בן מאיר נ' ראש הממשלה (בג"ץ 2109/20)** | איכון טלפונים בידי השב"כ בתחילת הקורונה, מכוח הסמכה כללית בחוק השב"כ | בשעת **דחיפות** — אפשר כהסדר זמני מכוח הסמכה כללית; כשהדחיפות חולפת — זה **הסדר ראשוני** שחייב להיקבע בחוק |

## 4.10 מלכודות נפוצות

! **שים לב — מלכודות נפוצות** לחשוב שתקנות או החלטות ממשלה יכולות להקנות סמכות — רק חקיקה ראשית. לחשוב שהסמכה כללית תמיד פסולה — היא מספיקה כשאין פגיעה בזכויות או בעיה לאומית.

## 4.11 שלד לפתרון שאלה — פרשנות הסמכה

## 4.12 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

| הטעות | למה היא שגויה | התיקון |
|---|---|---|
| לחשוב שהסמכה כללית מספיקה לכל פעולה לפרש תמיד בצמצום | כשהפגיעה בזכות חמורה נדרשת הסמכה מפורשת (קטלן, מאנע) | לדרוש רמת פירוט יחסית לפגיעה |
| | בעניין החתול אין פגיעה בזכויות אדם ולכן פרשנות רחבה | להבחין לפי עוצמת הפגיעה |
| לראות בהסדרים ראשוניים כלל חוקתי מוחלט | ברק ראה בו כלל פרשני; מעמדו נותר "צריך עיון" (יצוא גז) | לציין את המחלוקת |
| לחשוב שתקנות יכולות להסמיך לה | הסמכה מקורה בחקיקה ראשית; תקנות כפופות | לחפש את החוק המסמיך |
| להתעלם מתקנות שעת חירום | כוחן יפה לשנות חוק, אך יפורשו בצמצום ובדחיפות בלבד | לבחון דחיפות ותקופה |

## 4.13 תרגיל פתור — תקנה שמסמיכה חיפוש בגוף

## 4.14 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** מקור הסמכות הוא בחקיקה ראשית; תקנות כפופות לה. חוק הפרשנות מסדיר סוגיות כמו מועד הפעלה (ס' 11), ביטול תקנה (ס' 15), סמכויות עזר (ס' 17(ב)) ופעולה במספר אנשים (ס' 20).

## 4.15 מילון מושגים

## 4.16 נקודות מפתח למבחן

✔ **שורה תחתונה — עיקרי הפרק** מקור הסמכות — רק חקיקה ראשית; חוק הפרשנות ס' 11–20. כלל 1: חתול (רחב — אין פגיעה בזכויות) מול קטלן ומאנע (מפורש — פגיעה בזכויות); פלונית נ' קצין התגמולים; עליאן.

## 4.17 שאלות בסגנון המבחן

## 4.18 שאלות לחשיבה

## שרשרת פסיקה בפרק

| פסק דין | ההלכה |
|---|---|
| **בג"ץ 6446/96 העמותה למען החתול נ' עיריית ערד** | הלכה: סעיפי הכלבים, השרצים והחזירים אינם מסמיכים, אך סעיף 242(1) ("להסרת כל מטרד") כן. נקבע שהפרשנות הרחבה מותרת כאשר אין פגיעה בזכויות אדם, אולם לא בדרך של רעל. חשיבות למבחן: הצד הרחב של כלל פרשנות 1. |
| **בג"ץ 355/79 קטלן נ' שירות בתי הסוהר** | הלכה: "חיפוש בו" אינו מסמיך לבדיקה פולשנית, כי פגיעה חמורה בזכויות אדם מחייבת הסמכה חד-משמעית ומפורשת. בעקבות הפסק חוקק חוק חיפוש בגוף החשוד (1996). חשיבות למבחן: הצד הדווקני של כלל פרשנות 1. |
| **בג"ץ 6824/07 מאנע נ' רשות המסים** | הלכה: אין סמכות. כשפעולת הרשות עלולה לפגוע בזכות יסוד אין היא יוצאת ידי חובה בהצבעה על הוראת חוק כללית, וההסמכה צריכה להיות ברורה, מפורטת ומפורשת בחקיקה ראשית. חשיבות למבחן: הניסוח הקלאסי של כלל פרשנות 1. |
| **בג"ץ 2740/96 שנסי נ' המפקח על היהלומים** | הלכה: חשין העיר שההסמכה הגורפת "טופחת בחוזקה על פניו של עקרון שלטון החוק" ושהסדרים ראשוניים צריכים להיקבע בחוק. הוא לא הכריע בבטלות הצו והעתירה נדחתה. חשיבות למבחן: המקור לכלל ההסדרים הראשוניים. |
| **בג"ץ 3267/97 רובינשטיין נ' שר הביטחון** | הלכה: ברק קבע שהסדרים ראשוניים נקבעים בחקיקה ראשית כחזקה פרשנית שחוקי היסוד מחזקים, ושרמת ההפשטה המותרת תלויה בעוצמת הפגיעה ובצורך במומחיות. בעיה לאומית אינה בסמכות השר. חשין התמקד בפגיעה בשוויון. בעקבות הפסק נחקק חוק טל. חשיבות למבחן: פסק הדין המרכזי של כלל פרשנות 2. |
| **בג"ץ 11163/03 ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים נ' ראש הממשלה** | הלכה: ההחלטה הפלתה, וקביעת אזורי עדיפות היא הסדר ראשוני שבסמכות הכנסת בלבד, וההסמכה השיורית אינה מספיקה. המבחנים כוללים היקף השפעה, מחלוקת ציבורית ומשמעות כספית. חשיבות למבחן: התלכדות שני כללי הפרשנות. |
| **בג"ץ 4491/13 המרכז האקדמי למשפט ועסקים נ' ממשלת ישראל** | הלכה: דעת הרוב קבעה שהחזקה ניתנת לסתירה, ושכאשר אין פגיעה ממשית בזכויות די בהסמכה משתמעת; מעמד הכלל נותר "צריך עיון". המיעוט, השופט ג'ובראן, סבר שחשיבות ההחלטה מחייבת הסמכה מפורשת. חשיבות למבחן: השאלה הפתוחה האם הכלל חוקתי או פרשני. |
| **בג"ץ 616/11 התאחדות הסטודנטים הארצית נ' ממשלת ישראל** | הלכה: השופט רובינשטיין ראה בכלל ההסדרים הראשוניים כלל חוקתי, וקבע שהסעיף נוגד את חובת השוויון ובטל. בהמשך נקבע שעמדה זו אינה מחייבת. חשיבות למבחן: הגישה החוקתית לכלל. |

פרק 5

# מקורות הסמכות — סמכות שיורית, סמכות עזר, סמכות טבועה וסיווג סמכויות

## מקורות הסמכות וסיווגן

| מקור | תוכן | מגבלה |
|---|---|---|
| סמכות שיורית (ס' 32) | הממשלה עושה כל דבר בכפוף לכל דין שלא הוטל על רשות אחרת | נסוגה מפני חוק; לא לפגיעה בחירויות |
| סמכות עזר (ס' 17(ב)) | סמכויות הדרושות במידה המתקבלת על הדעת | נלווית; לא לפגיעה בזכויות; מחיר כן, אגרה/מס לא |
| ריבוי מקורות | בחירה בין חיקוקים שווי דרגה (פילצר) | מידתיות (יוחייב) |

| פסק דין | הלכה |
|---|---|
| קריית גת | הסדר בחוק – הסמכות השיורית נסוגה; "כל דין" כולל הלכה |
| פדרמן | בריק משפטי – סמכות שיורית לסיוע בינלאומי |
| איגוד העיתונים | חסות כן; פרסומות לא |
| מגן דוד אדום | פנימי רחב / חיצוני מצומצם; שכר – הסמכה מפורשת |
| פלונית | עזר לא לפגיעה בפרטיות |

| סוג סמכות | מבחן | עוצמת כללים |
|---|---|---|
| מעין-חקיקה | נורמה משנה משפט + כללית (הורנשטיין) | פרסום חזק |
| מעין-שפיטה | סכסוך בין שני צדדים (סלוק) | זכות טיעון חזקה |
| ביצוע | כל השאר | זכות טיעון בפגיעה (ברמן) |

✦ **הגדרה — סמכות חובה/רשות** אופנהיימר: בכל סמכות רכיב חובה (להפעיל בזמן סביר) ורכיב רשות (תוכן).

✦ **הגדרה — חריגה מסמכות** פעולה בניגוד לחוק היא חריגה מסמכות (למשל בנייה בלי היתר גם למשרד ממשלתי).

★ **טיפ למבחן — לבחינה** מצאו מקור; אם אין – עזר/שיורית; סווגו; קבעו עוצמת פרוצדורה.

! **שים לב — מלכודות** שיורית נסוגה מפני חוק; עזר אינו לפגיעה בזכות; "רשאי" אינו חופש מוחלט.

**מילות מפתח:** בכפוף לכל דין; במידה המתקבלת על הדעת; "שליח אינו עושה שליח"; כללי עוצמה; סכסוך בין שני צדדים.

## 5.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

## 5.2 הסמכות השיורית של הממשלה

§ **סעיף — 32 לחוק יסוד: הממשלה** (בעבר ס' 29, ואחר כך ס' 40): "הממשלה מוסמכת לעשות בשם המדינה, בכפוף לכל דין , כל פעולה שעשייתה אינה מוטלת בדין על רשות אחרת ."

## 5.3 עיריית קריית גת נ' מדינת ישראל (בג"ץ 2918/93)

## 5.4 יישומים נוספים של הסמכות השיורית

## 5.5 סמכויות עזר — ס' 17(ב) לחוק הפרשנות

§ **סעיף — ציטוט / הסעיף** "הסמכה לעשות דבר או לכפות עשייתו — משמעה גם מתן סמכויות עזר הדרושות לכך במידה המתקבלת על הדעת ."

## 5.6 סמכויות עזר בפסיקה

| סוג השידור | ההכרעה | הנימוק |
|---|---|---|
| תשדירי שירות שקופיות חסות | מותר<br>מותר — **סמכות עזר** | חלק מהסמכות המפורשת — אינפורמציה<br>נדרש להפעלת הסמכות הראשית, "במידה המתקבלת על הדעת"; פורמט מקובל בשידור ציבורי בעולם, ואינו פוגע במהותו הציבורית |

| | | |
|---|---|---|
| פרסומות מסחריות | **אסור** | סותר את מהות השידור הציבורי — אינו "מתקבל על הדעת" |

| מישור | תוכן | היקף סמכויות העזר |
|---|---|---|
| **חיצוני** | הפעלת הסמכויות כלפי הציבור (פינוי לבתי חולים, טיפול בחירום) | **מצומצם** |
| **פנימי** | הארגון שמשרת את המישור החיצוני — לוגיסטיקה, הכשרות, ציוד; זקוק לאוטונומיה, גמישות ויעילות | **רחב** |

## 5.7 סמכות טבועה מתוקף התפקיד

## 5.8 ריבוי מקורות סמכות

| פסק הדין | העובדות | ההלכה |
|---|---|---|
| **פילצר נ' שר האוצר (בג"ץ 171/69)** | הפקעות בשכונת ימין משה בירושלים לאחר 1967, לשיקומה כשכונת אמנים — לפי הפקודה, ולא לפי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (הידידותי יותר) | השופט **לנדוי**: "הפקודה והחוק הם שני מעשי חקיקה שווי דרגה, ואין בחוק... הוראה מפורשת השוללת משר האוצר את סמכותו לפעול לפי הפקודה". הרשות **רשאית לבחור** |
| **מהדרין נ' שר האוצר (בג"ץ 3028/94)** | הפקעת פרדסים להרחבת נמל התעופה בן גוריון — לפי הפקודה ולא לפי חוק התכנון והבנייה | גם אחרי חוקי היסוד: "שני מסלולים נפרדים, ובידי הרשות לבחור מסלול הנראה לה ביותר" |
| **יוחייב נ' התובע הצבאי הראשי (רע"פ 1057/99)** | מי שלא התייצב לגיוס טופל בדרך הקשוחה (ס' 49) ולא בדרך המקלה (ס' 12) בחוק שירות ביטחון | העתירה נדחתה, אבל נקבע: שיקול הדעת בבחירה בין סמכויות מקבילות **כפוף למבחן המידתיות** — "על הרשות להעדיף את הסמכות שפגיעתה קלה יותר, אלא אם קיימים שיקולים להעדיף את השנייה" |

## 5.9 סיווג סמכויות — חקיקה, ביצוע ומעין-שפיטה

| סוג | המבחן |
|---|---|
| **מעין-חקיקה** | (1) מופנית לציבור בלתי מסוים; **וגם** (2) משנה את המצב הנורמטיבי |
| **מעין-שפיטה** | הכרעה של צד שלישי (הגוף המנהלי) בסכסוך בין שני צדדים |
| **ביצוע** | כל השאר |

## 5.10 למה הסיווג חשוב — "כללי עוצמה"

| כלל | מעין-חקיקה | ביצוע | מעין-שפיטה |
|---|---|---|---|
| זכות טיעון | חלשה (מכתב שיועבר) | בינונית (שימוע, בלי חקירה נגדית) | חזקה (בכתב ובעל פה, עם עו"ד, עיון בטענות הצד שכנגד, חקירה נגדית) |
| חובת הנמקה | חלשה (דברי הסבר) | בינונית | חזקה (החלטה מפורטת) |
| סופיות | חלשה (אפשר לשנות) | בינונית | חזקה (אי אפשר לשנות אחרי שנמסרה) |
| איסור גיבוש עמדה מראש / עצמאות | חלש (חבר מועצה שננשך בידי כלב אינו פסול) | בינוני | חזק |
| פרסום | **חזק** — חובה, אחרת אין תוקף | בינוני | חלש — מסירה לצדדים |

## 5.11 סמכות חובה וסמכות רשות

## 5.12 פעולה בניגוד לחוק — חריגה מסמכות

## 5.13 מלכודות נפוצות

**! שים לב — מלכודות נפוצות** לחשוב שס' 32 מסמיך את הממשלה לפעול גם כשיש חוק בנושא — הסמכות נסוגה. לשכוח את דורנר: "כל דין" כולל הלכה פסוקה וזכויות יסוד.

## 5.14 שלד לפתרון שאלה — מציאת מקור לסמכות

## 5.15 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

| הטעות | למה היא שגויה | התיקון |
|---|---|---|
| להפעיל סמכות שיורית כשיש חוק | קריית גת: הסמכות השיורית נסוגה מפני הסדר בחוק | לבדוק אם הנושא מוסדר |
| להפעיל סמכות עזר כדי לפגוע בזכות | פלונית: סמכות עזר אינה מקור לפגיעה בזכויות יסוד | לדרוש הסמכה מפורשת |
| לגבות אגרה או מס מכוח עזר | אפשר מחיר בלבד; אגרה ומס מחייבים הסמכה | להבחין מחיר/אגרה/מס |
| לסווג בחירה בין מדחן לסדרן כמעין-חקיקה | הורנשטיין: זו פעולת ביצוע, אין שינוי במשפט | להפעיל את שני תנאי אגרנט |

| | | |
|---|---|---|
| לחשוב ש"רשאי" פירושו חופש מוחלט | אופנהיימר: יש רכיב חובה – להפעיל בזמן סביר | לבחון חובה/רשות לפי מהות הפעולה |

## 5.16 תרגיל פתור — רשות שידור, פרסומות ושקיפות

## 5.17 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** סמכות שיורית (ס' 32 לחוק יסוד: הממשלה): בכפוף לכל דין, ובלבד שלא מוטלת על רשות אחרת; נסוגה מפני הסדר בחוק (קריית גת); אינה מקור לפגיעה בחירויות.

## 5.18 מילון מושגים

## 5.19 נקודות מפתח למבחן

✔ **שורה תחתונה — עיקרי הפרק** ס' 32: "בכפוף לכל דין" + "אינה מוטלת בדין על רשות אחרת"; קריית גת — נסוגה מפני הסדר; דורנר — כולל הלכה וזכויות; פדרמן — ריק משפטי; שמאי הביטוח — מסלול מקביל רק אחרי בחינת החוק; עינויים — לא לפגיעה בחירות.

## 5.20 שאלות בסגנון המבחן

## 5.21 שאלות לחשיבה

## שרשרת פסיקה בפרק

| פסק דין | ההלכה |
|---|---|
| **בג"ץ 2918/93 עיריית קריית גת נ' מדינת ישראל** | הלכה: גולדברג קבע שמשקיים דין היוצר הסדר, נסוגה מפניו סמכות הממשלה, וס' 32 מפורש בצמצום; אך כשהחוק אינו מיושם בפועל ייתכן מסלול אחר. דורנר: "כל דין" כולל גם הלכה פסוקה וזכויות יסוד. חשיבות למבחן: גבולות הסמכות השיורית. |

**בג"ץ 5128/94 פדרמן נ' שר המשטרה** הלכה: שמגר קבע שבריק משפטי הסמכות השיורית כוללת קשרים וסיוע בינלאומי. העתירה נדחתה. חשיבות למבחן: הפעלה כדין של סעיף 32.

**בג"ץ 5062/97 איגוד שמאי הביטוח נ' מדינת ישראל** הלכה: העתירה נדחתה כתיאורטית. השופט אור הוסיף באגב שרק אחרי שהממשלה בחנה ענייני וסביר את הפעלת החוק והחליטה שלא להכריז, אפשר לפנות לסמכות השיורית. חשיבות למבחן: צמצום של קריית גת.

**בג"ץ 757/84 איגוד העיתונים היומיים נ' רשות השידור** הלכה: תשדירי שירות בסמכות מפורשת; חסות – סמכות עזר במידה המתקבלת על הדעת; פרסומות אסורות כי הן סותרות את המהות הציבורית של הרשות. חשיבות למבחן: הזיקה הנדרשת בין סמכות עזר לסמכות הראשית.

**ע"א 9657/03 מגן דוד אדום נ' הממונה על השכר** הלכה: השופט ג'ובראן הבחין בין מישור פנימי, שבו סמכויות העזר רחבות, למישור חיצוני שבו הן מצומצמות. תשלום שכר ליו"ר חורג מהניהול הפנימי ונדרשת הסמכה מפורשת. אפשר לגבות מחיר, אך לא אגרה ומס. חשיבות למבחן: גבולות סמכות העזר.

**רע"א 2558/16 פלונית נ' קצין התגמולים** הלכה: מגבלה יסודית על הכרה בסמכות עזר היא שאין היא משמשת לפגיעה בזכויות יסוד; מעקב פוגע בפרטיות, ולכן אין סמכות. חשיבות למבחן: סמכות עזר אינה מקור לפגיעה בזכויות.

**בג"ץ 171/69 פילצר נ' שר האוצר; רע"פ 1057/99 יוחייב** הלכה: בפילצר (לנדוי) – כששני חיקוקים שווי דרגה הרשות רשאית לבחור. ביוחייב – הבחירה כפופה למידתיות: להעדיף את הפוגעת פחות, אלא אם יש שיקולים לשנייה. חשיבות למבחן: ריבוי מקורות סמכות.

**ע"פ 74/58 היועץ המשפטי לממשלה נ' הורנשטיין** הלכה: אגרנט קבע שסמכות מעין-חקיקה מחייבת נורמה שמשנה את המשפט ושהיא כללית. קביעת מקום מוסדר ותעריף היא מעין-חקיקה שאין להעביר ("שליח אינו עושה שליח"); הבחירה בין מדחן לסדרן היא ביצוע. חשיבות למבחן: מבחן מעין-חקיקה.

**בג"ץ 3/58 ברמן נ' שר הפנים; בש"א 136/90 מדינת ישראל נ' סלוק** הלכה: בברמן קבע זילברג שגם החלטה שפוגעת באדם מחייבת שמיעה, ושמעין-שיפוט הוא הכרעה על סמך ממצאים במחלוקת בין שני צדדים. בסלוק: המבחן העיקרי הוא קיומו של סכסוך בין שני צדדים. חשיבות למבחן: מבחן מעין-שפיטה.

**בג"ץ 295/65 אופנהיימר נ' שרי הפנים והבריאות** הלכה: בכל סמכות רשות יש רכיב חובה (להפעיל בזמן סביר) ורכיב רשות (תוכן). השאלה פרשנית לפי מהות הפעולה. חשיבות למבחן: סיווג סמכויות לחובה ורשות.

פרק 6

# עצמאות שיקול הדעת — הלכת מיכלין, הנחיות מנהליות ונטילת סמכות

## עצמאות שיקול הדעת

✦ **הגדרה — שלושה עקרונות משנה** (1) איסור כבילת שיקול הדעת; (2) איסור דעה מוקדמת סגורה; (3) חובה להפעיל שיקול דעת עצמאי.

✔ **שורה תחתונה — הלכת מיכלין** שר ופקיד מוסמך חלוקים – מכריע הפקיד. החלטה לפי הוראת השר בלבד – בטלה.

| סייג | פסק דין / מקור |
|---|---|
| התייעצות מותרת | ארגוני הקבלנים; ניימן – "העיון העצמי" |
| אימוץ מדיניות אחרי בחינה | הרוקחים; שייב |
| הנחיות גמישות | חפציבה; סיעת למען התורה |
| נטילת סמכות | ס' 34 לחוק יסוד: הממשלה |
| אצילה | ס' 33; פיליפוביץ |

| תנאי נטילה (ס' 34) | פירוט |
|---|---|
| 1 | שר הממונה על ביצוע החוק |
| 2 | הסמכות נתונה לעובד מדינה (לא תאגיד סטטוטורי) |
| 3 | לא סמכות בעלת אופי שיפוטי |
| 4 | אין כוונה אחרת משתמעת מהחוק |

| | העברה | האצלה |
|---|---|---|
| קשר | מתנתק | המאציל יכול לבטל ולהנחות |
| דרישה | הסמכה מפורשת | חזקה שאסורה אלא אם הותרה |

§ **סעיף — סעיף 33 לחוק יסוד: הממשלה** אצילה לשר ולעובד ציבור (למעט התקנת תקנות). לגורם פרטי – רק בנסיבות מיוחדות (הנפלינג, תנו לחיות לחיות).

★ **טיפ למבחן — לבחינה** שאלו: מי החליט בפועל? התייעצות או הכתבה? יש הנחיה? נטילה או אצילה?

! **שים לב — מלכודות** לא כל התייעצות פסולה; נגיד בנק ישראל אינו עובד מדינה; הסתייעות שונה מאצילה.

**מילות מפתח:** רציו ואוביטר; שורה תחתונה; העיון העצמי; תהיינה הנסיבות אשר תהיינה; אין אחריות בלי סמכות; נימוקים חזקים במיוחד.

## 6.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

## 6.2 עקרון עצמאות שיקול הדעת — שלושה עקרונות משנה

| עיקרון משנה | תוכן | דוגמה |
|---|---|---|
| **1. איסור כבילת שיקול הדעת** (Non-Fettering) | אסור להתחייב מראש מה תחליט — ההחלטה הטובה תלויה בנסיבות ברגע ההחלטה | חברה תקים מפעל אם שר האוצר יתחייב שלא להעלות מסים 20 שנה — הוא אינו יכול: אולי תפרוץ מלחמה |
| **2. איסור דעה מוקדמת** | לבוא לקבלת ההחלטה בראש פתוח, לאסוף נתונים, לשמוע — ורק אז להחליט | בית חולים בבאר שבע או באשדוד — אסור לבוא "נעול" |
| **3. חובה להפעיל שיקול דעת עצמאי** | מי שהוסמך — הוא שקובע | הלכת מיכלין |

## 6.3 מיכלין נ' שר הבריאות (בג"ץ 70/50)

§ **סעיף — ציטוט / הסעיף** השופט דונקלבלום: "התקנה... מעניקה סמכות לרשות המפקחת... היא איננה מחייבת את הרשות המפקחת להישמע או להיכנע להוראותיו של השר הממונה עליה.

| חלק | התוכן |
|---|---|
| **הרציו** | השר רוצה א', הפקיד המוסמך רוצה ב' — קובע הפקיד |
| **האוביטר** | הפקיד רוצה ב', אבל בגלל השר קובע א' — ההחלטה **בטלה** |

## 6.4 התייעצות — מותרת, אבל ההחלטה שלך

§ **סעיף — ציטוט / הסעיף** "על בעל הסמכות רובצת החובה לבדוק את הנתונים; האחרים יכולים לקבצם, למיינם ולארגנם — ובלבד שלא יגרע משלמות התמונה ומדיוקה — והם רשאים אף לצרף עצותיהם, המלצותיהם או חוות דעותיהם, אך ההחלטה נופלת על יסוד העיון העצמי ולא על יסוד עיונם של אחרים."

## 6.5 הנחיות מנהליות

| צד | הנקודות |
|---|---|
| | יתרונות גיבוש יסודי, בלי לחץ של החלטה ספציפית; אחידות ושוויון; עיצוב מדיניות; ודאות לאזרח; ביקורת שיפוטית קלה יותר |
| | חסרונותנוקשות במקום גמישות — הפקיד "כבול" במקום להפעיל שיקול דעת |

## 6.6 נטילת סמכות — ס' 34 לחוק יסוד: הממשלה

§ **סעיף — ציטוט / הסעיף** "שר הממונה על ביצועו של חוק רשאי ליטול לעצמו כל סמכות, למעט סמכות בעלת אופי שיפוטי, הנתונה על פי אותו חוק לעובד המדינה, אם אין כוונה אחרת משתמעת מן החוק.

| תנאי | הסבר | דוגמה שבה התנאי אינו מתקיים |
|---|---|---|
| 1. השר **הממונה על** **ביצוע** החוק | לפי סעיף ההגדרות והביצוע בחוק | |
| 2. הסמכות נתונה ל**עובד המדינה** | עובדי משרדי הממשלה — לא רשויות מקומיות או תאגידים סטטוטוריים | שר האוצר אינו יכול ליטול את סמכות נגיד בנק ישראל לקבוע ריבית; שר הפנים אינו יכול ליטול סמכות ראש עירייה להסיר מטרד |
| 3. סמכות **שאינה שיפוטית** | לא סמכות להכריע בסכסוך | ועדת ערר לתכנון; המפקח על המקרקעין בסכסוכי בית משותף |
| 4. **אין כוונה אחרת** משתמעת מהחוק | פרשנות | שר הבריאות אינו יכול ליטול את סמכות הפסיכיאטר המחוזי לאשפוז כפוי (חוק טיפול בחולי נפש) |

## 6.7 העברה, האצלה והסתייעות

| פעולה | המשמעות | מתי מותר |
|---|---|---|
| **העברת סמכות** | הקשר בין בעל הסמכות לסמכות **מתנתק**; אינו יכול להחזירה או להנחות | רק בהסמכה מפורשת (למשל העברה משר לשר בחוק יסוד: הממשלה, באישור הכנסת) |
| **האצלת סמכות** | הקשר **אינו מתנתק**: המאציל יכול לבטל את ההאצלה ולהנחות את הנאצל; הנאצל הופך ל"רשות מוסמכת" — כפוף לכל הכללים וחשוף לביקורת | בהסמכה — מפורשת או **משתמעת** |
| **הסתייעות** | עזרה באיסוף נתונים או בפעולות טכניות; שיקול הדעת וההחלטה נשארים אצל בעל הסמכות | **חזקה שמותר**, אלא אם החוק אוסר |

§ **סעיף — 33 לחוק יסוד: הממשלה** הממשלה רשאית לאצול סמכות לשר; שר רשאי לאצול סמכות שלו (למעט התקנת תקנות ) לעובד ציבור — כולה, מקצתה או בסייגים.

## 6.8 האם הלכת מיכלין עוד קיימת?

## 6.9 מלכודות נפוצות

! **שים לב — מלכודות נפוצות** לחשוב שהלכת מיכלין בוטלה — היא קיימת, עם סייגים רבים. לחשוב שיש חזקה שפקיד שהחליט כמו השר לא הפעיל שיקול דעת — אין חזקה (ארגוני הקבלנים, הרוקחים).

## 6.10 שלד לפתרון שאלה — מי החליט באמת?

## 6.11 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

| הטעות | למה היא שגויה | התיקון |
|---|---|---|
| "כל התייעצות פוסלת את ההחלטה" | התייעצות מותרת; הפגם הוא כשהממונה מכתיב ולא נשאר שיקול דעת עצמאי | לבדוק אם נשמרה ההחלטה הסופית |
| להחיל את מיכלין בלי להזכיר סייגים | יש חמישה סייגים: התייעצות, אימוץ, הנחיות, נטילה, אצילה | לציין את הסייג הרלוונטי |
| לטעון שהנחיה מחייבת מוחלט | חפציבה: מדיניות נוקשה היא כבילה של שיקול דעת | לדרוש גמישות וסטייה מנומקת |

| | | |
|---|---|---|
| להפעיל ס' 34 על תאגיד סטטוטורי | הנגיד אינו עובד מדינה – אי אפשר ליטול ממנו סמכות | לבדוק את ארבעת התנאים |
| לבלבל העברה והאצלה | בהעברה הקשר מתנתק; באצילה המאציל נשאר ויכול לבטל ולהנחות | להבחין לפי הקשר הנמשך |

## 6.12 תרגיל פתור — ועדה שקיבלה "שורה תחתונה"

## 6.13 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** שלושה עקרונות משנה: איסור כבילת שיקול דעת, איסור דעה מוקדמת (סגורה), חובה להפעיל שיקול דעת עצמאי. מיכלין: כשהשר והפקיד המוסמך חלוקים – מכריע הפקיד; החלטה לפי הוראת השר בלבד – בטלה.

## 6.14 מילון מושגים

## 6.15 נקודות מפתח למבחן

✔ **שורה תחתונה — עיקרי הפרק** שלושה עקרונות משנה: איסור כבילה, איסור דעה מוקדמת, שיקול דעת עצמאי. מיכלין: רציו (הפקיד קובע) ואוביטר (החלטה לפי השר — בטלה).

## 6.16 שאלות בסגנון המבחן

## 6.17 שאלות לחשיבה

## שרשרת פסיקה בפרק

| פסק דין | ההלכה |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **בג"ץ 70/50 מיכלין נ' שר הבריאות** | הלכה: דונקלבלום קבע שהפקיד המוסמך אינו מחויב להישמע להוראות מישהו אחר, ואם יפעל לפי הוראות השר במקום לפי שיקול דעתו, פעולתו בטלה. רציו ואוביטר. חשיבות למבחן: יסוד הלכת העצמאות. |
| **בג"ץ 74/51 המרכז של ארגוני הקבלנים נ' שר המסחר** | הלכה: אין רע בכך שהפקיד מקבל עצה או הדרכה כל עוד ההחלטה הסופית היא שלו. הפקיד אימץ את המדיניות, והעתירה נדחתה. חשיבות למבחן: האוביטר הפך להלכה, אך אין חזקה שהפקיד פעל לפי הממשלה. |
| **ע"ב 2/84 ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות (עצמאות שיקול הדעת)** | הלכה: שמגר קבע שאחרים יכולים לאסוף ולייעץ, אך ההחלטה נופלת על יסוד העיון העצמי. הוועדה קיבלה רק שורה תחתונה ולא הפעילה שיקול דעת. חשיבות למבחן: גבול ההתייעצות. |
| **בג"ץ 4870/90 הסתדרות הרוקחים נ' שר הבריאות** | הלכה: מותר להתייעץ עם הממונה ולאמץ את מדיניותו אחרי בחינה עצמאית. העתירה נדחתה. חשיבות למבחן: סייג להלכת מיכלין. |
| **בג"ץ 2709/91 חפציבה נ' מינהל מקרקעי ישראל** | הלכה: השופט אור קבע שמדיניות שתחול "תהיינה הנסיבות אשר תהיינה" כמוה כהחלטה שלא להפעיל שיקול דעת. הנחיות הן גמישות. העתירה התקבלה. חשיבות למבחן: הנחיות אינן מחייבות באופן מוחלט. |
| **עע"מ 6726/10 סיעת למען התורה נ' המועצה הדתית צפת** | הלכה: רובינשטיין קבע שהיתר לסטות מהנחיה מוגבל, סטייה מחייבת נימוקים חזקים במיוחד ועמידה בדרישות דיוניות גבוהות, והביקורת קפדנית. ההליך בוטל. חשיבות למבחן: גבולות הגמישות. |
| **בג"ץ 2303/90 פיליפוביץ נ' רשם החברות** | הלכה: ברק קבע חזקה שאצילה אסורה אלא אם הותרה, גם במשתמע; אין חזקה נגד הסתייעות, ובלבד שלא תהיה שקולה כנגד האצלה. כאן מדובר בסיוע טכני. חשיבות למבחן: ההבחנה בין הסתייעות לאצילה. |
| **בג"ץ 839/82 הנפלינג נ' ראש עיריית אשדוד; בג"ץ 4884/00 תנו לחיות לחיות נ' מנהל השירותים הווטרינריים** | הלכה: בהנפלינג – סמכויות סטטוטוריות לא יוענקו לאדם פרטי שאינו חלק ממערכת שלטונית. בתנו לחיות לחיות – לחברה ניתן תפקיד של שיקול דעת, ובכלל סמכות שלטונית אינה ניתנת לאצילה לגורם פרטי אלא בנסיבות מיוחדות. חשיבות למבחן: גבול האצילה. |
| **בג"ץ 5016/96 חורב נ' שר התחבורה (עצמאות שיקול הדעת)** | הלכה: חשין העיר באגב שהשר שרשאי ליטול סמכות רשאי גם להורות לרשות מה להחליט; הביקורת היא על גוף ההחלטה ולא על גוף המחליט. דעת יחיד. חשיבות למבחן: הספקות לגבי הלכת מיכלין. |

פרק 7

# התשתית העובדתית — הלכת יורונט והראיה המנהלית

## התשתית העובדתית

✦ **הגדרה — חובת התשתית** כל החלטה נשענת על נתונים מספקים, רלוונטיים, אמינים ומוצקים. מקור: שלטון החוק ונאמנות (בז'רנו: לא על יסוד שמועות).

✔ **שורה תחתונה — יורונט** הרשות בחרה בדרך הקלה בלי עבודת מטה ובלי חלופות; הסעד – החזרה לרשות.

| תנאי | תוכן | דוגמה |
|---|---|---|
| איסוף | לאסוף את המידע הדרוש | מונא, הדרים, ברגר |
| רלוונטיות | סינון נתונים שאינם שייכים | סקאפי, מוסטקי |
| אמינות | ראיה מנהלית | לנסקי, מלבסקי, דותי, אייזנברג |
| מוצקות | עוצמה לפי חומרה | שללם, ג'ועמיס, ניימן |

✦ **הגדרה — ראיה מנהלית** ראיה שרשות סבירה הייתה רואה בה ערך הוכחתי וסומכת עליה; גמישה מדיני הראיות.

| פסק דין | ההלכה |
|---|---|
| לנסקי | עדות שמיעה מותרת אם אמינה |
| מלבסקי | מודיעין סודי כראיה מנהלית |
| אייזנברג | עבר פלילי נשקל גם אחרי חנינה |
| שללם | שלילת רישיון קיים – תשתית חזקה |

| רף נמוך |
|---|
| שומת מס – אומדנים (בן שלמה) |
| מבקשי מקלט – קשיים ראייתיים (גונזלס) |

★ **טיפ למבחן — לבחינה** ארבעה תנאים, הרף לפי חומרה, והסעד – החזרה לרשות (לא החלפת שיקול דעת).

! **שים לב — מלכודות** רשות אינה כפופה לדיני הראיות; נתונים ישנים פסולים; בית משפט לא מחליט במקום הרשות.

**מילות מפתח:** עבודת מטה; יורונט; ראיה מנהלית; עדות שמיעה; מוצקות; עדכניות; החזרה לרשות.

## 7.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

## 7.2 למה חובה? — שלטון החוק ונאמנות

## 7.3 הלכת יורונט (בג"ץ 987/94 יורונט קווי זהב נ' שרת התקשורת)

## 7.4 ארבעת התנאים לתשתית עובדתית (זמיר)

| # | התנאי | תוכן | דוגמאות מהפסיקה |
|---|---|---|---|
| 1 | **איסוף הנתונים** | לאסוף את המידע הדרוש — מילוי טפסים, איסוף אקטיבי, עבודת מטה, חוות דעת מומחים; לפעמים לפנות לרשות אחרת | מונא; מוניות הדרים; ברגר |
| 2 | **רלוונטיות** | להפריד בין נתונים שנוגעים לעניין לבין כאלה שאינם — מתחבר לאיסור השיקול הזר (פרק 10) | סקאפי |
| 3 | **אמינות** | מידע מהימן, בלי חשש להטיה או זיוף — מבחן "הראיה המנהלית"; רלוונטי במיוחד בעידן של חדשות כזב ובינה מלאכותית | לנסקי; מלבסקי; דותי; אייזנברג |
| 4 | **מוצקות** | מכלול רחב דיו כדי להסתמך עליו; ככל שההחלטה חשובה ופוגענית יותר — נדרשת תשתית מוצקה יותר | שללם; ג'ועמיס; ניימן; מוסטקי |

## 7.5 איסוף נתונים — יישומים

## 7.6 רלוונטיות

## 7.7 אמינות — מבחן הראיה המנהלית

| פסק הדין | הקביעה |
|---|---|
| **לנסקי נ' שר הפנים (בג"ץ 442/71)** | בשונה מהדין הפלילי, רשות רשאית להסתמך על **עדות שמיעה**, אם היא אמינה דיה לאדם סביר |
| **מלבסקי דותי** | אושר ביטול אזרחות על סמך **דו"ח מודיעיני סודי** שבו השתמש שר הפנים תשתית הנתונים לא עמדה בדרישות: סירוב לתת אזרחות מחשש שהמבקשת מחזיקה קטינה שלא כדין — בלי מסמכים מוכיחים |
| **אייזנברג נ' שר הבינוי והשיכון (בג"ץ 6163/92)** | במינוי מנכ"ל למשרד השיכון — יש ראיות מנהליות על עבר פלילי חמור של המועמד, שעל הרשות לשקול **גם אם ניתנה לו חנינה**; המינוי בוטל |

## 7.8 מוצקות — "ככל שההחלטה חמורה יותר"

## 7.9 תשתית עובדתית ועילות אחרות

| עילה | הקשר |
|---|---|
| חובת הנמקה | אין נימוק בלי עובדות |
| שיקולים זרים | התנאי השני (רלוונטיות) — סינון שיקולים שאינם שייכים |
| סבירות | אי אפשר לאזן נכון בין שיקולים בלי לדעת את העובדות (דפי זהב) |
| מידתיות | יורונט — היעדר בחינת חלופות הוביל לאמצעי פוגעני מהנדרש |

## 7.10 מלכודות נפוצות

**! שים לב — מלכודות נפוצות** לחשוב שרשות כפופה לכללי הראיות הפליליים — מבחן הראיה המנהלית גמיש יותר (לנסקי — עדות שמיעה). לחשוב שכל ראיה מספיקה — הרף עולה עם חומרת הפגיעה (שללם, ניימן).

## 7.11 שלד לפתרון שאלה — בחינת התשתית העובדתית

## 7.12 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

| הטעות | למה היא שגויה | התיקון |
|---|---|---|
| להחיל על הרשות דיני ראיות פליליים | הרשות אינה בית משפט; מבחן הראיה המנהלית גמיש (לנסקי) | לבחון אם אדם סביר היה סומך על המידע |
| לחשוב שכל ראיה מספיקה לצפות שבית המשפט יחליט במקום הרשות | הרף עולה עם חומרת הפגיעה (שללם, ניימן) יורונט: הסעד הוא החזרה לרשות | להתאים את הרף לחומרה לבקש החזרה לגיבוש תשתית |
| להתעלם ממועד הנתונים | ברגר ועדת השחרורים: נדרשים נתונים עדכניים | לבדוק את עדכניות המידע |
| לשכוח את החנינה כראיה | אייזנברג: ראיות על עבר חמור נשקלות גם אחרי חנינה | לשקול ראיות רלוונטיות גם אם הוענקה חנינה |

## 7.13 תרגיל פתור — ביטול רישיון על סמך שמועה

## 7.14 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** כל החלטה מנהלית חייבת להישען על תשתית עובדתית; מקור החובה בשלטון החוק ובנאמנות (בז'רנו: לא על יסוד שמועות). יורונט: עבודת מטה ובחינת חלופות; הסעד – החזרה לרשות.

## 7.15 מילון מושגים

## 7.16 נקודות מפתח למבחן

✔ **שורה תחתונה — עיקרי הפרק** מקור החובה: שלטון החוק, נאמנות; בז'רנו — "לא על יסוד שמועות". יורונט: עבודת מטה; חלופות; החזרה לרשות. ארבעה תנאים: איסוף, רלוונטיות, אמינות, מוצקות.

## 7.17 שאלות בסגנון המבחן

## 7.18 שאלות לחשיבה

## שרשרת פסיקה בפרק

| פסק דין | ההלכה |
|---|---|
| **בג"ץ 987/94 יורונט קווי זהב נ' שרת התקשורת** | הלכה: הרשות לא ביצעה עבודת מטה ולא גיבשה תשתית עובדתית אמינה, והפגיעה בחופש העיסוק לא הייתה מידתית. הסעד: החזרת העניין לרשות. חשיבות למבחן: הלכת היסוד של התשתית העובדתית. |
| **בג"ץ 442/71 לנסקי נ' שר הפנים** | הלכה: בשונה מהדין הפלילי אפשר להסתמך על עדות שמיעה; המבחן הוא ראיה שאדם סביר היה רואה בה ערך הוכחתי וסומך עליה. חשיבות למבחן: מבחן הראיה המנהלית. |
| **בג"ץ 6163/92 אייזנברג נ' שר הבינוי והשיכון** | הלכה: ראיות מנהליות על עבר פלילי חמור נשקלות גם אחרי חנינה. המינוי בוטל. חשיבות למבחן: ראיה מנהלית במינויים. |
| **בג"ץ שללם נ' פקיד רישוי כלי ירייה; בג"ץ ג'ועמיס נ' שר הפנים (מועצת זרזיר)** | הלכה: שלילת רישיון קיים מחייבת תשתית מעמיקה, חזקה ועדכנית; ביטול החלטה קודמת מחייב תשתית איתנה ולא שמועות. הרף עולה כשנפגעות זכויות יסוד. חשיבות למבחן: מוצקות לפי חומרה. |
| **בג"ץ ברגר נ' שר הפנים (שעון הקיץ); בג"ץ מונא נ' שר הפנים; בג"ץ מוניות הדרים נ' שר התחבורה** | הלכה: אין לדחות חוות דעת חדשות ולהישען על ישנות; לעיתים חובה להסתמך על נתוני רשות אחרת; יש להתחשב בנתונים רלוונטיים. חשיבות למבחן: התנאי הראשון, איסוף נתונים. |

פרק 8

# כללי הצדק הטבעי — שימוע, ניגוד עניינים, הנמקה והיוועצות

## כללי הצדק הטבעי

| כלל | מבחן | פסק דין |
|---|---|---|
| שימוע | פגיעה ישירה וממשית | ברמן |
| ניגוד עניינים אישי | חשש סביר (אובייקטיבי) | מושלב |
| ניגוד עניינים מוסדי | אפשרות ממשית | פתח תקווה |
| הנמקה | בקשה בכתב; 45 ימים | שפירא; חוק 1958 |
| היוועצות | מוקדמת, מלאה, בלב פתוח | עיר דוד; בוקובזה; אשקר |

✦ **הגדרה — שימוע** הודעה עם המידע הרלוונטי + שמיעה בפני הגורם המוסמך. מתכונת גמישה; בשימוע מאוחר הנטל על הרשות.

**! שים לב — חריגי שימוע** מעין-חקיקה; ויתור מדעת; דחיפות אובייקטיבית (סרטי נוח – לא אם הרשות יצרה אותה).

✔ **שורה תחתונה — ניגוד עניינים** כלל מניעתי: אל תביאוני לידי ניסיון. הסעד לפי עוצמה: נטרול נקודתי עד ביטול.

§ **סעיף — חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), 1958** בקשה בכתב – החלטה ותשובה בכתב בהקדם עד 45 ימים; סירוב – מנומק; חריג – ביטחון. אי-הנמקה מעבירה את הנטל לרשות.

✦ **הגדרה — היוועצות כהלכה** מוקדמת; מידע מלא; זמן סביר; לב פתוח. "קליפה ריקה" – פסולה.

★ **טיפ למבחן — לבחינה** לכל טענה פרוצדורלית: מקור החובה, תנאים, חריגים, יישום, סעד.

**מילות מפתח:** לב פתוח ונפש חפצה; מבחן הפגיעה; אל תביאוני לידי ניסיון; שורה תחתונה; לא על דרך הסתם.

## 8.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

## 8.2 זכות הטיעון — חובת השימוע

| ענף | רכיב | תוכן |
|---|---|---|
| מסירת הודעה | הודעה על הפגיעה הצפויה או על הטענות — עם **כל המידע הרלוונטי** הנחוץ כדי לטעון | |
| בפני הגורם המוסמך | עניינית (למעט מידע שחשיפתו פוגעת בביטחון, בסוד מסחרי או בצדדים שלישיים) | |
| זמן סביר | השימוע צריך להיות מול מי שמקבל את ההחלטה | |
| הזדמנות אפקטיבית | להתכונן; ככל שהפגיעה קשה יותר — יותר זמן | |
| | שהפרט יוכל באמת לנסות לשכנע | |

## 8.3 חריגים לחובת השימוע

| חריג | הסבר | דוגמה |
|---|---|---|
| **סמכות מעין-חקיקה** | תקנות מופנות לציבור רחב — שימוע לכל נפגע אינו יעיל | |
| **ויתור מדעת** | הרשות מסרה הודעה ונתנה זמן, והפרט ויתר | |
| **אינטרס נוגד** | בית המשפט ישקול | גירוש פעילי חמאס (1992) — חשש להתפרעויות וצורך מבצעי; |
| **חשוב יותר** | | הוכרה אפשרות של שימוע מאוחר בפני ועדות ערר |
| **דחיפות — "כורח השעה"** | נבחנת **אובייקטיבית** — האם באמת אין זמן, או שהרשות עצמה גרמה לכך | **סרטי נוח נ' המועצה לביקורת סרטים (בג"ץ 549/75):** יום לפני הקרנת בכורה ביקשה המועצה לבטל היתר בלי שימוע — "אין זמן". נדחה: הרשות לא הייתה צריכה לחכות לדקה ה-90 |

## 8.4 האיסור על ניגוד עניינים

| סוג | ההתנגשות | המבחן | דוגמה |
|---|---|---|---|
| **אישי** | אינטרס ציבורי שהעובד אמון עליו מול אינטרס **אישי** (משפחתי, כלכלי) | **חשש סביר** | **מושלב נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה:** תוכנית לקיבוץ כברי — לא נמצא שום פגם תכנוני, ובכל זאת ההחלטה נפסלה בשל חשש סביר לניגוד עניינים אישי |
| **מוסדי** | אינטרס שלטוני אחד מול אינטרס שלטוני אחר (שני "כובעים") | **אפשרות ממשית** | **סיעת הליכוד נ' עיריית פתח תקווה:** חבר מועצה שישב גם בוועדת ההנהלה (שמייעצת לראש העירייה) וגם בוועדת הביקורת (שמבקרת אותו) — קשה לבקר את עצמך |

## 8.5 חובת ההנמקה

✦ **הגדרה — חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), התשי"ט–1958** חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), התשי"ט–1958: נתבקש עובד ציבור בכתב להשתמש בסמכות שניתנה לו על פי דין — יחליט ויודיע למבקש בכתב בהקדם, ולא יאוחר מ- 45 ימים ; סירב — יודיע לו את נימוקי הסירוב .

## 8.6 חובת ההיוועצות הסטטוטורית

| סוג | התנאי | הסבר |
|---|---|---|
| פורמלי | **מוקדמת** | לפני ההחלטה (**בוקובזה נ' שר החינוך:** התייעצות על תקציב לרשויות מקומיות שהתקיימה אחרי שנת הלימודים ואישור התקציב — פסולה) |
| פורמלי | **מלוא המידע וזמן סביר** | כל החומר הרלוונטי, ומהות ההחלטה הצפויה; זמן לפי מורכבות, היכרות המייעץ ולוחות זמנים — אבל לא "עד אין קץ" |
| פורמלי | **היכרות מוקדמת אינה פוטרת** | גם אם עמדת המייעץ ידועה — חובה להתייעץ (ולעיתים שוב, אם חלף זמן) |
| מהותי | **דו-צדדית** | לשמוע ולהשמיע, לשכנע ולהשתכנע — שיח אמיתי |
| מהותי | **לב פתוח ונפש חפצה** | בלי דעה קדומה, מתוך רצון כן לשמוע (קשה להוכחה) |

## 8.7 מלכודות נפוצות

**! שים לב — מלכודות נפוצות** לחשוב שזכות הטיעון חלה רק בהליך מעין-שיפוטי — ברמן הרחיב. לקבל "דחיפות" שהרשות יצרה בעצמה — סרטי נוח. לבלבל בין מבחני ניגוד העניינים:

## 8.8 שלד לפתרון שאלה — פרוצדורה של קבלת החלטה

## 8.9 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

| הטעות | למה היא שגויה | התיקון |
|---|---|---|
| לדרוש שימוע בכל מקרה | אין שימוע במעין-חקיקה, בדחיפות אובייקטיבית או בוויתור | לבדוק חריגים |
| לטעון דחיפות שהרשות יצרה | סרטי נוח: הדחיפות נבחנת אובייקטיבית | לבחון מי גרם לדחיפות |

| | | |
|---|---|---|
| לדרוש הוכחת ניגוד עניינים בפועל | הכלל מניעתי: מספיק חשש סביר (אישי) או אפשרות ממשית (מוסדי) | להפעיל את המבחן המתאים |
| לבלבל הנמקה לפי החוק והנמקה כללית | החוק חל כשנתבקשה פעולה בכתב; חובות נוספות נובעות מהפסיקה | לבדוק מה הפעיל את החוק |
| לראות בהיוועצות פורמליות בלבד | "קליפה ריקה" אינה מקיימת את החובה; נדרשת היוועצות בלב פתוח | לבחון את מהות ההיוועצות |

## 8.10 תרגיל פתור — חבר ועדה שהוא גם בעל קרקע

## 8.11 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** שימוע: קם בפגיעה ישירה וממשית (ברמן); מתכונת גמישה; חריגים – ויתור, דחיפות אובייקטיבית (סרטי נוח), מעין-חקיקה; בשימוע מאוחר הנטל על הרשות.

## 8.12 מילון מושגים

## 8.13 נקודות מפתח למבחן

✔ **שורה תחתונה — עיקרי הפרק** שימוע: ברמן — מבחן הפגיעה; ענף פסיבי (הודעה, גורם מוסמך) ואקטיבי (זמן, הזדמנות); מוגבר במעין-שפיטה. חריגים: מעין-חקיקה, ויתור, אינטרס נוגד, דחיפות (סרטי נוח); שימוע מאוחר — הנטל על הרשות.

## 8.14 שאלות בסגנון המבחן

## 8.15 שאלות לחשיבה

## שרשרת פסיקה בפרק

| פסק דין | ההלכה |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **בג"ץ 3/58 ברמן נ' שר הפנים (זכות הטיעון)** | הלכה: מבחן הפגיעה – פגיעה ישירה וממשית מחייבת לאפשר לנפגע לטעון, גם בסמכות ביצוע; היקף השימוע וצורתו תלויים בנסיבות. חשיבות למבחן: מקור זכות הטיעון. |
| **בג"ץ 549/75 סרטי נוח נ' המועצה לביקורת סרטים** | הלכה: הדחיפות נבחנת אובייקטיבית; הרשות לא הייתה צריכה להמתין לרגע האחרון, והטענה נדחתה. חשיבות למבחן: דחיפות שהרשות יצרה אינה פוטרת משימוע. |
| **בג"ץ מושלב נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה** | הלכה: אף שלא נמצא פגם תכנוני, ההחלטה נפסלה בשל חשש סביר לניגוד עניינים אישי. חשיבות למבחן: מבחן החשש הסביר, מניעתי ואובייקטיבי. |
| **סיעת הליכוד נ' עיריית פתח תקווה** | הלכה: אפשרות ממשית לניגוד עניינים מוסדי, כי קשה לבקר את עצמך. חשיבות למבחן: מבחן האפשרות הממשית. |
| **בג"ץ 142/70 שפירא נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין (הנמקה)** | הלכה: חובה לנמק גם בגוף רב-חברים, שחבריו מצביעים כל אחד מטעמיו, במיוחד שם יש חשש לשיקולים פסולים. חשיבות למבחן: היקף חובת ההנמקה. |
| **בג"ץ 512/81 המכון לארכיאולוגיה נ' שר החינוך (עיר דוד)** | הלכה: שלושה פגמים – זמן קצר מדי, מידע חלקי, והחלטה מראש תחת לחצים; ההיוועצות פסולה. חשיבות למבחן: התנאים הפורמליים והמהותיים להיוועצות. |
| **בג"ץ בוקובזה נ' שר החינוך** | הלכה: היוועצות מאוחרת פסולה; היוועצות צריכה להיות מוקדמת. חשיבות למבחן: תנאי המועד. |
| **אשקר נ' משיח; איגוד מכוני הרישוי נ' שרת התחבורה (2024)** | הלכה: הנטייה לקבל את עמדת המייעץ; אפשר לסטות, אך לא על דרך הסתם אלא בנימוקים מבוססים, ומשקל רב יותר לגוף מומחה. בשני המקרים העתירה התקבלה. חשיבות למבחן: היוועצות אינה טקס. |

פרק 9

# פרסום תקנות והוראות מנהל ותחילת תוקף

## פרסום ותחילת תוקף

✦ **הגדרה — תקנה בת-פועל תחיקתי** נורמה כללית (לציבור בלתי מסוים) + נורמטיבית (חדשה). חייבת פרסום ברשומות (ס' 17 לפקודת הפרשנות).

| סוג | פרסום ברשומות |
|---|---|
| תקנה בת-פועל תחיקתי | חובה |
| הוראת מינהל | פטורה |
| הנחיה פנימית | פטורה, אך עיון לפי ס' 6(א) |
| תמרור (רונן) | תוכן – נורמה; הצבה – נתון עובדתי |

| פסק דין | ההלכה |
|---|---|
| אלכסנדרוביץ' | שני סממנים מצטברים; כתב אישום בוטל |
| האז | רק הכנסת פוטרת, עם פרסום חלופי; הסיפא – מועד תחילה |
| רונן | תמרור – פטור בהצבה |
| אזרזר | בטלות יחסית |
| אפרתי | הנחיות פנימיות – לא ברשומות, אך לידיעת הציבור |
| המל"ג נ' הארץ | צריך טעם ממשי לחריג |

✔ **שורה תחתונה — תחילה** ברירת מחדל – יום הפרסום; עתידית רצויה; רטרואקטיבית בעייתית: עבירה חדשה, תשלום על שירות שניתן, שלילת הטבה.

★ **טיפ למבחן — לבחינה** סווגו; בדקו פרסום ופטור; קבעו תוצאה (בטלות יחסית); בדקו מועד תחילה.

! **שים לב — מלכודות** שם (צו/הודעה) אינו קובע; רק הכנסת פוטרת; בטלות אינה מוחלטת.

**מילות מפתח:** אין חוקי סתר; כללית ונורמטיבית; בטלות יחסית; לא כל חובות הפרסום נולדו שוות; ממשל פתוח.

## 9.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

## 9.2 חובת הפרסום ברשומות

§ **סעיף — 17 לפקודת הפרשנות** (ההוראה הקלאסית שהפסיקה פירשה): "תקנה בת-פועל תחיקתי תפורסם ברשומות, ותחילת תוקפה ביום פרסומה, אם אין הוראה אחרת בעניין זה."

★ **טיפ למבחן — מה לעשות במבחן** אל תחפשו רק את המילה "תקנה". גם "צו", "הוראה" או "הודעה" מכוח חוק עשויים להיות תקנה בת-פועל תחיקתי.

## 9.3 מבחן "תקנה בת-פועל תחיקתי" — אלכסנדרוביץ' (ע"פ 213/56)

| סממן | תוכן |
|---|---|
| **1. כלליות** | נורמה **כללית ומופשטת** — מופנית לציבור כולו או לחלק בלתי מסוים ממנו; לא "שמית" — לא לאדם או לאנשים הנקובים בשמם |
| **2. נורמטיביות** | קובעת **נורמה משפטית חדשה** ובכך משנה את המשפט הנוהג |

## 9.4 פטור מפרסום — מי רשאי לפטור?

## 9.5 מה קורה כשלא פרסמו?

| תקופה | התוצאה |
|---|---|
| בעבר | אי-פרסום → **בטלות מוחלטת** (void), כמו כל פגם (אלכסנדרוביץ') |
| היום | **בטלות יחסית** — "לא כל חובות הפרסום נולדו שוות" |

## 9.6 מועד תחילת התוקף

## 9.7 פרסום הוראות מנהל והנחיות מנהליות

§ **סעיף 6(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח–1998** "רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור".

## 9.8 פומביות ושקיפות — המסגרת

## 9.9 חוק חופש המידע

| סעיף | תוכן |
|---|---|
| 1 | "לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה" — **בלי צורך להראות אינטרס** |
| 3 | חובת מינוי **ממונה על חופש המידע** בכל רשות (ועמדתו משפיעה מאוד על היישום) |
| 5 | דו"ח שנתי של הרשות על פעילותה, תפקידיה וסמכויותיה |
| 6 | פרסום הנחיות מנהליות וחוקי עזר |
| 7 | נוהל הגשת בקשות ולוחות זמנים |
| 8–9 | **חריגים** — מידע שאין למסור (ביטחון, פרטיות) או שאין חובה למסור (דיונים פנימיים, הקצאת משאבים בלתי סבירה, ועוד) |
| 16 | מידע על אדם עצמו שאינו נכון — זכות לבקש תיקון |
| 17 | **עתירה מנהלית** על אי-מסירת מידע |

## 9.10 מלכודות נפוצות

! **שים לב — מלכודות נפוצות** לחשוב שרק מסמך בשם "תקנה" חייב פרסום — גם צו או הודעה מכוח חוק. לשכוח שהסממנים מצטברים (כללי + נורמטיבי).

## 9.11 שלד לפתרון שאלה — פרסום ותחילת תוקף

## 9.12 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

| הטעות | למה היא שגויה | התיקון |
|---|---|---|
| לחשוב שכל הוראה מנהלית חייבת פרסום ברשומות | רק תקנה בת-פועל תחיקתי; הוראת מינהל והנחיה פנימית פטורות | לבדוק את שני הסממנים |

| | | |
|---|---|---|
| להתמקד בשם ("צו", "הודעה") להסיק בטלות מוחלטת מאי-פרסום | אלכסנדרוביץ': הצו נבחן לפי תוכנו, לא כותרתולנתח את המהות כיום – בטלות יחסית (אזרזר) | לאזן בין הפגיעה בפרט לאינטרס הציבורי |
| לחשוב שמתקין התקנות רשאי לפטור רק הכנסת, בחוק, ובלבד שיש פרסום חלופי (האז) את עצמו | | לחפש פטור בחקיקה ראשית |
| להתעלם מהבעיה של רטרואקטיביות עקרונות חוק העונשין אוסרים להעניש על מה פלילית | שלא היה אסור | לבדוק עבירה חדשה |

## 9.13 תרגיל פתור — צו שלא פורסם

## 9.14 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** תקנה בת-פועל תחיקתי (כללית + נורמטיבית) חייבת פרסום ברשומות; הוראת מינהל והנחיה פנימית לא. פטור מפרסום – רק הכנסת, בחוק, עם פרסום חלופי (האז); תמרור – נתון עובדתי (רונן).

## 9.15 מילון מושגים

## 9.16 נקודות מפתח למבחן

✔ **שורה תחתונה — עיקרי הפרק** ס' 17 לפקודת הפרשנות: חובת פרסום לתקנה בת-פועל תחיקתי. אלכסנדרוביץ': כלליות + נורמטיביות; כתב האישום בוטל. האז: רק הכנסת פוטרת; פרסום חלופי; "אין חוקי סתר".

## 9.17 שאלות בסגנון המבחן

## 9.18 שאלות לחשיבה

## שרשרת פסיקה בפרק

| פסק דין | ההלכה |
|---|---|
| **ע"פ 213/56 היועץ המשפטי לממשלה נ' אלכסנדרוביץ'** | הלכה: תקנה בת-פועל תחיקתי היא נורמה כללית ונורמטיבית, שני סממנים מצטברים. הצו חייב פרסום; מאחר שלא פורסם, כתב האישום בוטל. חשיבות למבחן: המבחן היסודי לתקנה בת-פועל תחיקתי. |
| **ע"פ 421/61 מדינת ישראל נ' האז** | הלכה: הסיפא "אם אין הוראה אחרת" מתייחסת למועד התחילה בלבד; רק הכנסת רשאית לפטור מפרסום, ובלבד שיהיה פרסום חלופי. אין חוקי סתר. חשיבות למבחן: גבולות הפטור. |
| **ע"פ 402/63 רונן נ' היועץ המשפטי לממשלה** | הלכה: תוכן התמרור נורמה שחייבת פרסום; הצבתו נתון עובדתי המפעיל את הנורמה ופטורה. חשיבות למבחן: חריג לחובת הפרסום. |
| **אזרזר נ' משרד האוצר (2023)** | הלכה: לא כל חובות הפרסום שוות; התוצאה היא בטלות יחסית לפי היקף הפגיעה בפרט מול האינטרס הציבורי ופרסום חלופי. עתירת מי שהסתמך על המידע התקבלה. חשיבות למבחן: בטלות יחסית בפרסום. |
| **בג"ץ 5537/91 אפרתי נ' אוסטפלד** | הלכה: הנחיות פנימיות אינן תקנה בת-פועל תחיקתי ואינן חייבות פרסום ברשומות, אך יש להביאן לידיעת הציבור כשיש להן חשיבות לציבור. כיום – ס' 6(א) לחוק חופש המידע. חשיבות למבחן: פרסום הנחיות. |
| **עע"מ 9135/03 המועצה להשכלה גבוהה נ' הוצאת עיתון הארץ** | הלכה: אין די בהשתייכות לחריג; הרשות צריכה להראות טעם ממשי. הזכות למידע היא מאבני היסוד של חברה חופשית, והחוק כפוף למשפט המנהלי (מידתיות וסבירות). חשיבות למבחן: שקיפות כעיקרון. |

פרק 10

# שיקולים זרים, שוויון והפליה

## שיקולים זרים ושוויון

✦ **הגדרה — כלל השיקולים** חיובי: לשקול כל שיקול רלוונטי; שלילי: לא לשקול שיקול זר. מקור – תכלית החקיקה ועקרונות היסוד (ויכסלבוים).

| מקרה | כלל | דוגמה |
|---|---|---|
| קל – שיקול זר בלבד | ההחלטה נפסלת | רסקין, קומפורטי, לזרוביץ', מיטראל |
| קשה – שיקולים מעורבים | השפעה ממשית פוסלת (ברגר) | ברגר, דוויקאת (דומיננטית) |
| הצעת חשין (אגב) | מבחן ערכי: פסול בעליל – גם בהשפעה כלשהי | רונן |

| מבחן | תוכן |
|---|---|
| השפעה כלשהי | הקל לעותר – נדחה |
| אלמלא | אלמלא השיקול הזר – החלטה אחרת? |
| דומיננטי | המטרה העיקרית |
| בלעדי | הקשה לעותר |
| ממשית | ההלכה בברגר |

✔ **שורה תחתונה — הוכחה** מכלול ראיות; סטטיסטיקה יוצרת חזקה בעובדה (מוסקוביץ); מגמה: מסובייקטיבי לאובייקטיבי (סבירות).

| | חוקתי | מנהלי |
|---|---|---|
| שוויון | איסור הפליה מטעמים חשודים | יחס זהה למצבים זהים, אלא אם יש שוני רלוונטי |

✦ **הגדרה — שרירותיות טבועה** שרירות בלתי נמנעת בקביעת גבול (גיל, מרחק, תאריך) – לגיטימית לשם יעילות וודאות.

★ **טיפ למבחן — לבחינה** זהו תכלית; אילו שיקולים זרים; מקרה קל או קשה; מבחן ברגר; הוכחה; שוויון.

**! שים לב — מלכודות** אופי השיקול אינו קובע; לא נדרשת כוונה בהפליה; גת – הבחנה עניינית אינה הפליה.

**מילות מפתח:** מטרייה נורמטיבית; השפעה ממשית; דומיננטית; חזקה בעובדה; הפליה תוצאתית; שוני רלוונטי.

## 10.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

## 10.2 מהו שיקול דעת, ולמה בית המשפט נזהר

| עמדה | הנימוק |
|---|---|
| נגד התערבות | המחוקק נתן את שיקול הדעת לרשות, לא לשופט; לשופט אין יתרון על הרשות |
| בעד התערבות | שיקול דעת מוחלט עלול להוביל לשימוש לרעה; בעל סמכות שאינו מפוקח יכול "להכשיר" כל החלטה ע"י עמידה בפרוצדורה |

## 10.3 כלל השיקולים הזרים — שני פנים

| פן | הציווי |
|---|---|
| **חיובי** | לשקול **את כל** השיקולים הרלוונטיים |
| **שלילי** | לא לשקול **אף** שיקול שאינו רלוונטי |

## 10.4 "המקרה הקל" — שיקול זר בלבד

## 10.5 "המקרה הקשה" — שיקולים מעורבים: הלכת אמה ברגר

| # | מבחן | מתי ההחלטה פסולה | קושי לעותר |
|---|---|---|---|
| 1 | **בלעדיות** | השיקול הזר היה היחיד; השאר — הסוואה | הכי קשה |
| 2 | **הכרעה** ("אלמלא") | אלמלא השיקול הזר — ההחלטה הייתה אחרת | ↓ |
| 3 | **דומיננטיות** | השיקול הזר היה העיקרי | ↓ |
| 4 | **השפעה ממשית** | לשיקול הזר הייתה השפעה ממשית | ↓ |
| 5 | **השפעה כלשהי** | כל השפעה | הכי קל |

## 10.6 איך מוכיחים שיקול זר?

## 10.7 שוויון והפליה

| | שוויון חוקתי | שוויון מנהלי |
|---|---|---|
| התוכן | איסור הפליה מטעמים "חשודים": דת, גזע, מין, צבע, מוצא — פגיעה מבזה היא פגיעה בכבוד האדם | חובה לתת **יחס זהה למצבים זהים**; אסור להבחין בלי **שוני רלוונטי** |
| אילו טענות היא מבססת | שיקולים זרים (שקלו דת/גזע/מין), וגם חוסר סבירות, חוסר מידתיות, אי-מתן משקל ראוי לזכויות | חוסר חוסר סבירות, חוסר מידתיות, אי-מתן משקל ראוי — ואי-מתן משקל ראויאבל **לא** בהכרח שיקול זר (סירוב לסגירת מרפסת שונה מהשכן אינו בהכרח משיקול זר) |

## 10.8 מלכודות נפוצות

**! שים לב — מלכודות נפוצות** לשכוח את הפן החיובי — אי-שקילת שיקול רלוונטי (ויכסלבוים, פורז) היא פגם. לחשוב שכל השפעה של שיקול זר פוסלת — ההלכה:

## 10.9 שלד לפתרון שאלה — שיקולים זרים והפליה

## 10.10 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

| הטעות | למה היא שגויה | התיקון |
|---|---|---|
| לפסול כל החלטה שנגע בה שיקול זר | לפי ברגר פוסלת רק השפעה ממשית; השפעה כלשהי אינה מספיקה | להעריך את עוצמת ההשפעה |
| לחשוב שחומרת השיקול משנה במבחן ברגר | ההלכה: אופי השיקול אינו משנה, רק עוצמת ההשפעה (חשין הציע מבחן ערכי באגב) | להבחין בין הלכה להצעה |
| לדרוש כוונת הפליה | שדולת הנשים: ההפליה נבחנת גם במבחן התוצאה | לבדוק את התוצאה בפועל |
| לראות בכל קו גבול הפליה | שרירותיות טבועה בקביעת גבול היא לגיטימית | לבחון עניינות וסבירות הגבול |
| לראות בפגיעה בשוויון תמיד שיקול זר | היא מבססת לעיתים חוסר סבירות או מידתיות ולא בהכרח שיקול זר | לשייך את הטענה לעילה הנכונה |

## 10.11 תרגיל פתור — מכרז ושיקול נוסף

## 10.12 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** כלל השיקולים: פן חיובי (לשקול הרלוונטי) ופן שלילי (לא לשקול זר). מקור השיקולים – תכלית החקיקה (ויכסלבוים). מקרה קל: שיקול זר בלבד – החלטה נפסלת (רסקין, קומפורטי, לזרוביץ').

## 10.13 מילון מושגים

## 10.14 נקודות מפתח למבחן

✔ **שורה תחתונה — עיקרי הפרק** ריסון: "לא יחליף את שיקול דעתה"; חזקת החוקיות (ברעלי — גם לטובת הפרט). שני פנים: לשקול את כל הרלוונטיים (ויכסלבוים — "מטרייה נורמטיבית"; פורז), ולא לשקול זרים.

## 10.15 שאלות בסגנון המבחן

## 10.16 שאלות לחשיבה

## שרשרת פסיקה בפרק

| פסק דין | ההלכה |
|---|---|
| **בג"ץ 5688/92 ויכסלבוים נ' שר הביטחון** | הלכה: ברק קבע שהשיקולים הרלוונטיים נגזרים מתכלית החקיקה, מטרותיה הספציפיות ועקרונות היסוד של השיטה, כמטרייה נורמטיבית. השר לא שקל את כבוד האדם, והעתירה התקבלה. חשיבות למבחן: הפן החיובי של כלל השיקולים. |
| **בג"ץ 465/89 רסקין נ' המועצה הדתית ירושלים** | הלכה: סעיף 11 לחוק איסור הונאה בכשרות מתיר התחשבות בדיני כשרות בלבד; צניעות אינה חלק מכשרות המזון, ולכן היא שיקול זר. ההחלטה נפסלה. חשיבות למבחן: "המקרה הקל". |

| | |
|---|---|
| **בג"ץ 392/72 ברגר נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה** | הלכה: נבחנו חמישה מבחנים לשיקולים מעורבים; ההלכה היא שהשפעה ממשית של השיקול הזר פוסלת, ואילו השפעה כלשהי אינה פוסלת. אופי השיקול אינו משנה. העתירה התקבלה. חשיבות למבחן: ההלכה לשיקולים מעורבים. |
| **בג"ץ 390/79 דוויקאת נ' ממשלת ישראל (אלון מורה)** | הלכה: במבחן המטרה הדומיננטית נקבע שהשיקול העיקרי היה אידיאולוגי ואינו ענייני לפגיעה בקניין; נפסק לפנות. חשיבות למבחן: יישום מבחן הדומיננטיות. |
| **בג"ץ 706/94 רונן נ' שר החינוך** | הלכה: החנינה בוטלה כי לשיקול השקרי הייתה השפעה מכרעת. חשין הציע באגב מבחן ערכי: שיקול פסול בעליל, כמו הפליה או מרמה, יפסול גם בהשפעה כלשהי. ברגר לא שונתה. חשיבות למבחן: הצעת מבחן מדורג לפי חומרה. |
| **בג"ץ 571/89 מוסקוביץ נ' מועצת השמאים** | הלכה: ממכלול ראיות – סטטיסטיקה, דו"ח מבקר המדינה, ועדת הכנסת, מומחים בלתי תלויים ועדויות – הוכחה מדיניות הכשלה, שהיא שיקול זר. ברק: סטטיסטיקה יוצרת חזקה בעובדה המעבירה את נטל ההסבר לרשות. חשיבות למבחן: הוכחת שיקולים זרים. |
| **בג"ץ שדולת הנשים בישראל נ' ממשלת ישראל** | הלכה: הפליה נבחנת גם במבחן התוצאה; אם בפועל אין נשים, זו הפליה גם בלי הוכחת כוונה. חשיבות למבחן: הפליה תוצאתית. |
| **קיבוץ יחיעם; גני חוגה; המון ווליום נ' ממשלת ישראל** | הלכה: שרירותיות טבועה בכל קביעת גבול לגיטימית לשם יעילות וודאות, אך יעילות וודאות אינן חזות הכל. חשיבות למבחן: הבחנה מותרת. |

פרק 11

# עילת הסבירות

## עילת הסבירות

| תקופה | גישה | פסק דין |
|---|---|---|
| ותיקה | אבסורד – Wednesbury | דיזנגוף |
| דקה | עילה עצמאית; משקל מעוות; קיצוניות | דקה |
| מודרנית | ארבע פרופוזיציות; כל אקט; מתחם | דפי זהב |
| הפעלה | החלטה שלא להעמיד לדין | גנור |

✦ **הגדרה — ארבע הפרופוזיציות (ברק)** עילה עצמאית; אמות מידה אובייקטיביות; חוסר סבירות קיצוני; משקל לא ראוי לאינטרסים.

| סוג מקרה | מה בודקים | דוגמה |
|---|---|---|
| 1 | זכות יסוד מול אינטרס ציבורי – ההתערבות הלגיטימית ביותר | אינדור |
| 2 | שני שיקולים מקצועיים – בית המשפט לא מתערב | ירדן ההררי; חריג: צוקר |
| 3 | פגיעה בשלטון החוק ובאמון הציבור | דרעי–פנחסי; אייזנברג |

✔ **שורה תחתונה — מתחם הסבירות** טווח של החלטות לגיטימיות; פוסלים רק חריגה קיצונית, גם אם היה בוחר אחרת.

| בעד | נגד |
|---|---|
| חוסר ודאות נפתר בפסיקה מצטברת; כלי אחרון מונע החלטות קיצוניות | הפרדת רשויות: השקפת השופט מול השקפת הרשות הכשרה ערכית להחלטות סבירות |

| שנים אחרונות | תוצאה |
|---|---|
| שיינפלד | מינוי דרעי נפסל (סבירות / מניעות); שטיין – כלל שיורי; מינץ – מתחם רחב |
| תיקון 2023 | אסר דיון בסבירות החלטות הממשלה |
| 5658/23 | התיקון בוטל 8–7; 12–3 לסמכות לבקר חוקי יסוד; סולברג – חזרה ל-Wednesbury |

★ **טיפ למבחן — לבחינה** סווגו סוג מקרה, זהו משקל לא ראוי, הפעילו מתחם, וציינו את המצב העכשווי.

! **שים לב — מלכודות** לא נדרש חוסר תום לב; לא כל חלופה טובה יותר פוסלת; העילה חלה על כל אקט.

**מילות מפתח:** Wednesbury; משקל בפרופורציה מעוותת; מתחם הסבירות; בחינה de novo; הכשרה ערכית; כלל שיורי.

## 11.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

## 11.2 הגישה הוותיקה — חוסר סבירות כחוסר היגיון

## 11.3 דקה נ' שר התחבורה (בג"ץ 156/75) — עילה עצמאית של איזון

§ **סעיף — ציטוט / הסעיף** חוסר הסבירות מתבטא בדרך כלל בהפליה, בשיקולים זרים, באי-שקילת שיקול מהותי — "אולם... יכולה אי-הסבירות גם להתגלות כאשר היא בגפה :

## 11.4 דפי זהב נ' רשות השידור (בג"ץ 389/80) — ברק מול לנדוי

## 11.5 גנור נ' היועמ"ש (בג"ץ 935/89) — העילה בפעולה

| כיוון | השיקולים |
|---|---|
| בעד העמדה לדין | עבירות ממושכות, בחשאיות; פגיעה קשה באלפי אזרחים ובקופה הציבורית; עניין ציבורי בענישה ובהרתעה |
| נגד (שהיועמ"ש העדיף) | הוקעה ציבורית בדו"ח ועדת בייסקי; הבנקאים הודחו; אשמה גם של רשויות המדינה; זמן רב שחלף; עלות ההליך |

## 11.6 שלושה סוגי מקרים

| סוג | השיקולים המתנגשים | דוגמה | מידת הלגיטימיות |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | זכות יסוד מול אינטרס ציבורי | **אינדור נ' ראש עיריית ירושלים (בג"ץ 953/89):** הפגנה מול הקונסוליה האמריקאית; הקונסול התלונן, וההפגנה פוזרה. ניתן משקל גדול מדי ליחסי החוץ ומשקל קטן מדי **לחופש הביטוי** — לא סביר | נתפס כלגיטימי |
| 2 | שני אינטרסים מקצועיים שאינם זכויות יסוד | **התנועה לאיכות השלטון נ' המועצה הארצית (בג"ץ 2324/91):** תחנת כוח הידרו-חשמלית בירדן ההררי — אנרגיה ירוקה מול שמירת טבע; בית המשפט **לא התערב**. אבל **צוקר נ' שר הפנים (בג"ץ 581/87):** השר הטיל וטו על תוכנית אצטדיון טדי בטענה שנדרש תכנון כולל (ובעיתון — חילול שבת); הווטו נפסל — כנראה מתוך חשד לשיקולים זרים שלא הוכחו | חריג ביותר — בעיקר כשההחלטה "לא הגיונית" |
| 3 | אינטרס ציבורי מול **שלטון החוק ואמון הציבור** | גנור; **אייזנברג** (מינוי מנכ"ל שהיה מעורב בפרשת קו 300 וקיבל חנינה — לא סביר); **דרעי–פנחסי** | שנוי במחלוקת ביותר |

## 11.7 הלכת דרעי–פנחסי (1993)

## 11.8 בעד ונגד עילת הסבירות

| נושא | נגד העילה | בעד העילה |
|---|---|---|
| הפרדת רשויות ודאות | המחוקק נתן את שיקול הדעת לרשות — למה השקפת השופט על "סביר" תגבר על השקפת השר? אין אמות מידה; היועץ המשפטי אינו יודע אם החלטה תעמוד | ביקורת שיפוטית היא חלק מהאיזונים והבלמים, במיוחד להגנה על זכויות גם ברשלנות הסבירות נקבעת בדיעבד; הפסיקה המצטברת משרטטת את המתחם |
| לגיטימציה | "הכשרה ערכית": כשבית המשפט קובע שהחלטה סבירה, הוא נותן לה גם לגיטימציה ערכית (למשל הריסת בתי מחבלים) | ביקורת אפקטיבית חשובה גם מול גורמים בינלאומיים — שהמעשים נבחנו לגופם |

## 11.9 התקופה האחרונה — שיינפלד, התיקון לחוק היסוד וביטולו

| נימוק | פירוט ושופטים |
|---|---|
| חוסר סבירות קיצוני | פגיעה באמון הציבור; הרשעה חוזרת; מאסר על תנאי; המצג לבית המשפט — חיות, פוגלמן, עמית, כבוב, ברון, גרוסקופף (וגם וילנר — בגישה מרוסנת) |
| השתק / מניעות אי-הכרעה | המצג שהציג לבית המשפט בהסדר הטיעון — שטיין, מינץ (וגם ברק-ארז ווילנר במצטבר) הפנייה לשאלת הקלון — אלרון |

## 11.10 מלכודות נפוצות

**! שים לב — מלכודות נפוצות** לחשוב שכל החלטה "לא טובה" אינה סבירה — נדרשת חריגה קיצונית ממתחם הסבירות. לחשוב שחוסר סבירות מחייב שיקול זר או חוסר תום לב — עילה עצמאית (דקה).

## 11.11 שלד לפתרון שאלה — עילת הסבירות

## 11.12 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

| הטעות | למה היא שגויה | התיקון |
|---|---|---|
| לבלבל סבירות עם חוסר היגיון גרידא | מאז דקה ודפי זהב זו גם עילה איזונית – משקל מעוות לשיקולים רלוונטיים | להצביע על משקל לא ראוי |
| לפסול כל החלטה שבית המשפט היה מחליט אחרת | נדרשת חריגה קיצונית ממתחם הסבירות | לציין "קיצוני" |
| לדרוש חוסר תום לב | העילה עצמאית וקיימת גם בתום לב | לא להוכיח כוונה |
| לראות בה עילה רק לתקנות | דפי זהב: חלה על כל אקט מנהלי | להחיל על החלטות פרטניות |
| להתעלם ממצבה הנוכחי | התיקון לחוק היסוד בוטל ב-5658/23, ובכל זאת נשמעו קריאות לריסון | לציין את המחלוקת והמגמה |

## 11.13 תרגיל פתור — החלטה שלא להעמיד לדין

## 11.14 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** הגישה הוותיקה (Wednesbury, דיזנגוף): אבסורד שאין שר סביר שיעשה. דקה: עילה עצמאית של משקל מעוות; דפי זהב: ארבע פרופוזיציות, חלה על כל אקט, מתחם סבירות; לנדוי מזהיר מבחינה de novo.

## 11.15 מילון מושגים

## 11.16 נקודות מפתח למבחן

✔ **שורה תחתונה — עיקרי הפרק** Wednesbury ודיזנגוף — חוסר היגיון; קישור לסמכות; תקנות. דקה — עילה עצמאית; משקל מעוות; גם בתום לב; קיצוני. דפי זהב — ארבע הפרופוזיציות; כל אקט; ברק מול לנדוי; מתחם הסבירות.

## 11.17 שאלות בסגנון המבחן

## 11.18 שאלות לחשיבה

## שרשרת פסיקה בפרק

| פסק דין | ההלכה |
|---|---|
| **ע"א 311/57 היועץ המשפטי לממשלה נ' מ' דיזנגוף ושות'** | הלכה: התקנות נפסלו כבלתי הגיוניות עד שאדם בר-דעת לא יעלה על דעתו ששר סביר היה מסוגל לעשותן. חשיבות למבחן: הגישה הוותיקה, חוסר היגיון בנוסח Wednesbury. |
| **בג"ץ 156/75 דקה נ' שר התחבורה** | הלכה: שמגר קבע שאי-סבירות יכולה להתגלות בגפה, כשניתן משקל בפרופורציה מעוותת לשיקולים רלוונטיים גם בתום לב; נדרשת אי-סבירות קיצונית. העתירה נדחתה. חשיבות למבחן: עילה עצמאית של איזון. |
| **בג"ץ 389/80 דפי זהב נ' רשות השידור** | הלכה: ברק קבע ארבע פרופוזיציות – עילה עצמאית, אמות מידה אובייקטיביות, חוסר סבירות קיצוני, משקל ראוי – והחילה על כל אקט מנהלי. לנדוי התריע מבחינה מחדש של תבונת ההחלטה. העתירה נדחתה. חשיבות למבחן: יסוד הגישה המודרנית ומתחם הסבירות. |
| **בג"ץ 935/89 גנור נ' היועץ המשפטי לממשלה** | הלכה: ההחלטה בלתי סבירה באופן קיצוני, משום משקל לא ראוי לשיקולים; נקבע שיועמדו לדין על סמך עילת הסבירות בלבד. חשיבות למבחן: הפעלת העילה בפועל. |
| **בג"ץ 953/89 אינדור נ' ראש עיריית ירושלים** | הלכה: ניתן משקל גדול מדי ליחסי החוץ וקטן מדי לחופש הביטוי, ולכן ההחלטה לא סבירה. חשיבות למבחן: סוג 1 – זכות יסוד מול אינטרס ציבורי. |
| **בג"ץ 3094/93 התנועה לאיכות השלטון נ' ממשלת ישראל (דרעי); בג"ץ 4267/93 אמיתי נ' ראש הממשלה (פנחסי)** | הלכה: ההחלטה שלא לפטר אינה סבירה כי אינה נותנת משקל ראוי לאמון הציבור בשלטון החוק; "רשאי" לפטר פירושו "חייב" בכתב אישום חמור עם קלון. חשיבות למבחן: סוג 3, הלכה שנויה במחלוקת. |

**בג"ץ 8948/22 שיינפלד נ' הכנסת**

הלכה: המינוי נפסל – רוב על בסיס חוסר סבירות קיצוני, אחרים על בסיס השתק או מניעות. שטיין: סבירות ככלל שיורי; מינץ: מתחם רחב ביותר להרכבת ממשלה. חשיבות למבחן: מגמת ריסון ומעבר לעילות אחרות.

**בג"ץ 5658/23 התנועה לאיכות השלטון נ' הכנסת**

הלכה: ברוב של 12 מול 3 נקבעה סמכות לבקר חוקי יסוד במקרים קיצוניים, וברוב של 8 מול 7 התיקון בוטל. גם שופטים מהרוב קראו לצמצם את השימוש בעילה. חשיבות למבחן: מצב העילה כיום.

פרק 12

# עילת המידתיות ומשקל ראוי לזכויות יסוד

## עילת המידתיות

§ **סעיף — סעיף 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו** פגיעה בזכות רק בחוק ההולם את ערכי המדינה, לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש.

| מבחן | שאלה | דימוי / פסיקה |
|---|---|---|
| 1. התאמה | קשר רציונלי בין אמצעי למטרה | בן עטיה – נכשל |
| 2. אמצעי שפגיעתו פחותה | יש חלופה פחות פוגענית שמשיגה אותה רמה? | "החייט המינהלי"; הגדרת מטרה ורמת הישג (בית סוריק) |
| 3. מובן צר | תועלת מול נזק | בחינה יחסית (בית סוריק) |

✔ **שורה תחתונה — אחיו הבכור** הסבירות היא "אחיו הבכור" של המידתיות. המבחנים מצטברים לרשות וחלופיים לעותר.

| סבירות | מידתיות |
|---|---|
| ותיקה – היגיון (דיזנגוף) | התאמה |
| איזונית (דקה, דפי זהב) | מובן צר |
| מתחם סבירות | מתחם התחשבות; בחירת הפוגע הכי פחות |

✦ **הגדרה — אי-מתן משקל ראוי לזכויות יסוד** טענה עצמאית או מצטברת: מקבל ההחלטה לא נתן לזכות משקל ראוי.

| פסק דין | הלכה |
|---|---|
| בן עטיה | כשל בשלושה מבחנים |
| בית סוריק | כשל במובן צר |
| השונית 10 | הרוב אישר, המיעוט פסל |
| קצין התגמולים נ' פלוני | שוויון + סבירות + מידתיות |
| אל-טאיי | משך החזקה מול ביטחון |

★ **טיפ למבחן — לבחינה** זהו זכות ומטרה; עברו על שלושת המבחנים לפי סדר; הוסיפו משקל ראוי, סבירות ושוויון.

! **שים לב — מלכודות** לא לדלג על הגדרת המטרה; לא חובה לבחור את הפוגע הפחות בכל מקרה (מתחם התחשבות).

**מילות מפתח:** קשר רציונלי; החייט המינהלי; בחינה יחסית; מתחם התחשבות; אחיו הבכור; פסקת ההגבלה.

## 12.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

## 12.2 המקור — פסקת ההגבלה

§ **סעיף — 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו** "אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש , או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו ."

## 12.3 בן עטיה נ' שר החינוך (בג"ץ 3477/95)

| מבחן | תוכן (בלשון ברק) | היישום בבן עטיה |
|---|---|---|
| **1. התאמה (קשר רציונלי)** | "האמצעי צריך להוביל באופן רציונלי להגשמתה של המטרה" | **נכשל:** אין קשר בין העתקות בעבר (בבגרות החיצונית) לבין הבטחת טוהר הבחינות בעתיד אצל תלמידים אחרים, ובבחינה פנימית |
| **2. האמצעי שפגיעתו פחותה** | "החייט המינהלי צריך לתפור את החליפה המינהלית... תוך בחירה באמצעי הפוגע פחות באדם" | **נכשל:** אפשר להגביר פיקוח, להוסיף משגיחים, להסביר ולחנך |
| **3. מידתיות במובן הצר** | "יחס ראוי בין התועלת לציבור לבין הנזק לאזרח... אם יגרום... נזק כבד לאזרח, ואילו התועלת הצפויה לציבור אינה אלא מזערית — אסור" | **נכשל:** נזק לתלמידים, למורים שלא חטאו, למוניטין של בית הספר — מול תועלת מזערית |

## 12.4 בית סוריק נ' ממשלת ישראל (בג"ץ 2056/04) — מידתיות יחסית

## 12.5 יישומים נוספים

## 12.6 מידתיות מול סבירות — האם יש הבדל?

| מבחן מידתיות | המקבילה בסבירות |
|---|---|
| 1. התאמה בין אמצעי למטרה | סבירות "צרה" (דיזנגוף) — החלטה לא הגיונית. כל מה שאין בו התאמה — גם אינו הגיוני |
| 3. התועלת מול הנזק | סבירות "רחבה" — איזונית (דקה, דפי זהב): משקל ראוי לשיקולים |
| 2. האמצעי שפגיעתו פחותה | **כאן אולי ההבדל:** במידתיות — חובה לבחור את האמצעי הפוגעני **ביותר פחות**; בסבירות — די לבחור **אחת** מההחלטות שבתוך מתחם הסבירות |

## 12.7 אי-מתן משקל ראוי לזכויות יסוד

| עילה | הניסוח |
|---|---|
| חוסר סבירות | לא ניתן משקל נכון לשיקולים הרלוונטיים — חופש הביטוי מול הסדר הציבורי |
| חוסר מידתיות | לא נבחר האמצעי שפגיעתו בחופש הביטוי פחותה (הגבלת שעות, מקום, מספר משתתפים); והנזק לחופש הביטוי עולה על התועלת לסדר |
| אי-מתן משקל ראוי לזכויות יסוד | לא ניתן משקל ראוי לזכות היסוד לחופש הביטוי |

## 12.8 מפה — שילוב העילות בתיק אחד

| פגם | מבסס גם... |
|---|---|
| הפליה מטעם חשוד (דת, גזע, מין) | שיקול זר + סבירות + מידתיות + משקל ראוי לזכויות |
| הפליה "מנהלית" (יחס שונה למצבים זהים) | סבירות + מידתיות + משקל ראוי (לא בהכרח שיקול זר) |
| היעדר תשתית עובדתית / חלופות | מידתיות (מבחן 2) — יורונט |

## 12.9 מלכודות נפוצות

**! שים לב — מלכודות נפוצות** לחשוב שמספיק שהאמצעי מקדם את המטרה — צריך לעבור את שלושת המבחנים. לבחון "אמצעי שפגיעתו פחותה" בלי להגדיר קודם את רמת ההישג הנדרשת (בית סוריק).

## 12.10 שלד לפתרון שאלה — מבחני המידתיות

## 12.11 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

| הטעות | למה היא שגויה | התיקון |
|---|---|---|
| לדלג על הגדרת המטרה | בלי מטרה ורמת הישג אי אפשר לבחון חלופות (בית סוריק) | להגדיר מטרה ורמת הישג |
| לדרוש שההחלטה תיכשל בכל המבחנים | לרשות המבחנים מצטברים; לעותר מספיק כשל באחד | להצביע על המבחן הרלוונטי |
| לטעון שהרשות חייבת את האמצעי הפוגעני הפחות בכל מקרה | יש "מתחם התחשבות" ויכולות כמה דרכים לציין את המתחם | |
| לבלבל מידתיות במובן הצר עם אמצעי פחותהאחרון בוחן חלופות; הצר משווה תועלת לנזק פוגעני | | להפריד בין המבחנים |
| לעבור מיד למידתיות בלי לזהות זכות | המידתיות פועלת בעיקר כשנפגעת זכות; לזהות את הזכות והיקפה | להתחיל בזכות |

## 12.12 תרגיל פתור — סגירת דרך

## 12.13 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** מקור: פסקת ההגבלה בס' 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו; בן עטיה הרחיב למשפט המנהלי. שלושה מבחני משנה: התאמה, אמצעי שפגיעתו פחותה, מידתיות במובן הצר; מצטברים לרשות, חלופיים לעותר.

## 12.14 מילון מושגים

## 12.15 נקודות מפתח למבחן

✔ **שורה תחתונה — עיקרי הפרק** ס' 8 לחוק יסוד: כבוד האדם — "במידה שאינה עולה על הנדרש" חל גם על החלטות מכוח חוק. בן עטיה:

## 12.16 שאלות בסגנון המבחן

## 12.17 שאלות לחשיבה

## שרשרת פסיקה בפרק

| פסק דין | ההלכה |
|---|---|
| **בג"ץ 3477/95 בן עטיה נ' שר החינוך** | הלכה: ברק קבע שהמידתיות היא כאחיו הבכור עקרון הסבירות, ושלושה מבחני משנה – התאמה, אמצעי שפגיעתו פחותה, מידתיות במובן הצר. ההחלטה נכשלה בשלושתם והעתירה התקבלה. חשיבות למבחן: פסק הדין המכונן של המידתיות המנהלית. |
| **בג"ץ 2056/04 מועצת הכפר בית סוריק נ' ממשלת ישראל (מידתיות)** | הלכה: מבחן 1 עמד; מבחן 2 עמד לאחר הגדרת רמת הביטחון הנדרשת; מבחן 3 נכשל בבחינה יחסית – הפחתה מעטה בביטחון חוסכת נזק משמעותי. התוואי נפסל. חשיבות למבחן: מידתיות יחסית. |
| **עע"מ 1036/16 נציגות הבית המשותף ברחוב השונית 10 הרצליה נ' משרד התיירות** | הלכה: הרוב (דנציגר) סבר שזכות הקניין מוגבלת מלכתחילה והמתווה עומד בשלושת המבחנים. המיעוט (שהם) סבר שאינו האמצעי שפגיעתו פחותה. חשיבות למבחן: היישום תלוי בהיקף הזכות. |
| **עע"מ 7335/10 קצין התגמולים נ' פלוני** | הלכה: העתירה התקבלה בשלוש עילות – פגיעה בשוויון (משך ההליך אינו שוני רלוונטי), חוסר סבירות (משקל יתר לתקציב) וחוסר מידתיות. חשיבות למבחן: שילוב עילות בתיק אחד. |
| **אל-טאיי נ' שר הפנים (1995)** | הלכה: נדרש איזון בין משך ההחזקה לצורכי הביטחון; החזקה ממושכת ללא תכלית ממשית אינה מידתית. חשיבות למבחן: מידתיות בפגיעה בחירות. |

פרק 13

# עילות הסף וערכאות השיפוט — בג"ץ ובית המשפט לעניינים מנהליים

## ערכאות ועילות סף

| פורום | סמכות / מאפיין |
|---|---|
| בג"ץ | ערכאה ראשונה ואחרונה; 15(ג) שיורית; 15(ד) ספציפיות; צו על תנאי; דיון נוסף שאינו זכות |
| בית משפט לעניינים מנהליים (2000) | עתירה, ערעור, תובענה; צו ביניים; העברה לבג"ץ (ס' 6) |
| בית דין לעבודה / ועדות ערר | לפי החוק (למשל ביטוח לאומי) |

| הליך מנהלי | תוספת | ערעור לעליון |
|---|---|---|
| עתירה | ראשונה | בזכות |
| ערעור מנהלי | שנייה | ברשות |
| תובענה (פיצוי במכרז) | שלישית | בזכות |

| עילת סף | תוכן | פסיקה |
|---|---|---|
| עמידה | נפגע ישיר / עותר ציבורי | רסלר; קורן; אמסלם |
| שפיטות | נורמטיבית ומוסדית | רסלר |
| פנייה מוקדמת / מיצוי | לרשות; לאפיקים אחרים | |
| שיהוי | סובייקטיבי, אובייקטיבי, שלטון החוק | לשכת עוה"ד; 45 ימים |
| בשלות | יישום; אינטרס ממשי | סבח / חסון |
| תלויה ועומדת | להצטרף | כספי; 2024 – ריכוך |
| ניקיון כפיים | הסתרת עובדות | |
| מעשה עשוי | פעולה בלתי הפיכה | |
| תיאורטית | שאלה לא "על השולחן" | |

✔ **שורה תחתונה — שיהוי** שלושה יסודות: סובייקטיבי (צידוק), אובייקטיבי (נזק), שלטון החוק (חומרת הפגם).

★ **טיפ למבחן — לבחינה** ראשית פורום, אחר כך עילות סף לפי סדר, ורק אז מהות.

**! שים לב — מלכודות** בג"ץ אינו ערכאת ערעור; צו על תנאי רק בבג"ץ; עילות הסף יצירה שיפוטית.

**מילות מפתח:** מיני-בג"ץ; סעד למען הצדק; רב על ריב לא לו; נפגע במשתמע; הלכת כספי; עתירה תיאורטית.

## 13.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

## 13.2 חלק א': הערכאות

## 13.3 שתי הערכאות

| | בג"ץ | בית המשפט לעניינים מנהליים |
|---|---|---|
| מהו | בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק — "בית המשפט המנהלי של המדינה" | בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ("מיני-בג"ץ"); הוקם ב-**2000** להקלת העומס על בג"ץ |
| מעמד | ערכאה ראשונה ואחרונה; **עותרים** (לא מערערים); אין ערעור — אפשר רק לבקש **דיון נוסף** (לא זכות מוקנית) | על פסק דינו — **ערעור לבית המשפט העליון** |
| סמכות | **שיורית** — מה שלא בסמכות ערכאה אחרת | לפי **חוק בתי משפט לעניינים מנהליים, התש"ס–2000** והתוספות לו |

## 13.4 בית המשפט לעניינים מנהליים — שלושה הליכים (ס' 5)

| הליך | מתי | דוגמאות | ערעור לעליון |
|---|---|---|---|
| **עתירה מנהלית** | בעניינים שב**תוספת הראשונה** | חופש המידע, ארנונה, חינוך, רישוי עסקים, רישיונות נשק, עובדים זרים ואשרות שהייה | **בזכות** |
| **ערעור מנהלי** | בעניינים שב**תוספת השנייה** | ערעור על רשם האגודות השיתופיות; על בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין; על **שלילת רישיון נהיגה מטעמים רפואיים** (ס' 55א לפקודת התעבורה) | **ברשות** (כי זו כבר ערכאה שנייה) |
| **תובענה מנהלית** | בעניינים שב**תוספת השלישית** | תביעת **פיצויים** שעילתה במכרז (המכרז כבר בוצע, ואי אפשר לבטלו) | **בזכות** |

## 13.5 בג"ץ — הסמכות

§ **סעיף — 15(ג) לחוק יסוד: השפיטה — הסמכה כללית** בג"ץ ידון "בעניינים אשר הוא רואה צורך לתת בהם סעד למען הצדק ואשר אינם בסמכותו של בית משפט או של בית דין אחר" — שני תנאים מצטברים:

§ **סעיף — 15(ד) — ארבע הסמכות ספציפיות** (קודם בודקים את הספציפיות; אם אף אחת אינה מתאימה — חוזרים לכללית):

| # | הצו | כלפי מי | מתי |
|---|---|---|---|
| 1 | **הביאס קורפוס** ("הביאו את גופו") | מי שמחזיק אדם | שחרור מי שנעצר או נאסר שלא כדין — חשיבות יתרה מאז שהחירות הפכה לזכות יסוד (ס' 5 לחוק יסוד: כבוד האדם) |
| 2 | **מנדמוס** (צו עשה / אל תעשה) | רשויות המדינה, רשויות מקומיות ופקידיהן, וגופים ואנשים הממלאים **תפקיד ציבורי על פי דין** (שני תנאים: תפקיד בעל אופי ציבורי + על פי דין) | לפעול לפי חובותיהם. (מפעל הפיס — זיכיון לפי דין, ייעוד ציבורי: כן; פעילות וולונטרית שאינה לפי דין: לא) |
| 3 | **צו לבתי משפט ובתי דין ייחודיים** | בית הדין לעבודה, תעבורה, נוער, משפחה וכו' — **לא** שלום, מחוזי, עליון, ולא בתי דין דתיים | ערכאת **פיקוח**, לא ערעור; מתערב רק ב**טעות מהותית** |
| 4 | **צו לבתי הדין הדתיים** | בתי הדין הרבניים ושאר הדתיים | רק ב**חריגה מסמכות** (צר מהשלישי) |

| צו | בג"ץ | בית משפט לעניינים מנהליים |
|---|---|---|
| צו על תנאי | ✓ (חובה — כל עתירה) | ✗ |
| צו ביניים | ✓ | ✓ |

## 13.6 חלק ב': עילות הסף

## 13.7 למה יש עילות סף?

| המחיר | התועלת |
|---|---|
| פגיעה בזכות הגישה; החלטה פגומה עלולה להישאר בתוקף | ויסות עתירות ומניעת "הצפה"; סינון עותרים טורדניים (גם בהוצאות); יעילות ושמירה על זמן שיפוטי; סדר ומניעת שרירות; והגנה על הלגיטימיות המוסדית של בית המשפט |

## 13.8 זכות עמידה

## 13.9 שפיטות

| סוג | השאלה | המצב |
|---|---|---|
| **נורמטיבית** (שאלת הכלים) | האם יש לבית המשפט נורמות וכלים להכריע? | מאז שהסבירות הפכה לעילה עצמאית — כמעט **הכל שפיט נורמטיבית** |
| **מוסדית** (שאלת הכדאיות) | האם בית המשפט הוא המוסד המתאים? האם הדיון יפגע באמון הציבור בו? | נשארת שיקול, בעיקר בעתירות פוליטיות |

## 13.10 פנייה מוקדמת ומיצוי הליכים

## 13.11 שיהוי — שלושה יסודות

| יסוד | השאלה |
|---|---|
| **שיהוי סובייקטיבי** | האם יש לעותר **צידוק** לאיחור? |
| **שיהוי אובייקטיבי** | האם הדיון עכשיו יגרום **נזק** למשיבה או לצדדים שלישיים תמי לב? (אפשר לדחות גם בלי אשמת העותר — בניין מגורים מאוכלס שמונה שנים) |
| **הפגיעה בשלטון החוק** | פגם חמור ושורשי (חריגה מסמכות, שחיתות) — הנטייה לדון **חרף** השיהוי |

## 13.12 בשלות (עתירה מוקדמת)

## 13.13 ניקיון כפיים, עתירה תלויה ועומדת, מעשה עשוי, עתירה תיאורטית

## 13.14 מלכודות נפוצות

> **! שים לב — מלכודות נפוצות** לחשוב שמערערים לבג"ץ — עותרים; ואין ערעור על בג"ץ (רק דיון נוסף). לחשוב שבוחרים ערכאה לפי רצון — לפי החוק והתוספות.

## 13.15 שלד לפתרון שאלה — לאן פונים ואם עומדים בסף

## 13.16 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

| הטעות | למה היא שגויה | התיקון |
|---|---|---|
| להגיש בג"ץ כשיש ערכאה מתאימה | סעד "למען הצדק" ניתן רק בעניין שאינו בסמכות ערכאה אחרת (15(ג)) | לבדוק את התוספות לחוק |
| לחשוב שיש ערעור בזכות על פסק דין של בג"ץ | בג"ץ ערכאה ראשונה ואחרונה; אפשר בקשה לדיון נוסף שאינה זכות | לא "ערעור" אלא עתירה/דיון נוסף |
| לבלבל פנייה מוקדמת עם מיצוי הליכים | הראשונה לרשות עצמה, השנייה לאפיקים משפטיים אחרים | להפריד |
| להתעלם מהיסוד האובייקטיבי בשיהוי | גם עותר שאינו אשם עלול להידחות בשל נזק לצדדים שלישיים | לבחון שלושה יסודות |
| להניח שעותר ציבורי תמיד נדחה | הרחבת זכות העמידה מאפשרת עותר ציבורי; דחייה כשיש נפגע ישיר שלא פנה | לבדוק מי הנפגע הישיר |

## 13.17 תרגיל פתור — עתירה שאיחרה

## 13.18 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** בג"ץ – ערכאה ראשונה ואחרונה (ס' 15(ג) סעד למען הצדק; 15(ד) ביאס קורפוס, מנדמוס, בתי דין); דיון נוסף אינו זכות.

## 13.19 מילון מושגים

## 13.20 נקודות מפתח למבחן

✔ **שורה תחתונה — עיקרי הפרק** בג"ץ: שיורי, ראשון ואחרון, עתירה; ס' 15(ג) (סעד למען הצדק + לא בסמכות אחרת) ו-15(ד) (ארבעה צווים). בית משפט לעניינים מנהליים (2000):

## 13.21 שאלות בסגנון המבחן

## 13.22 שאלות לחשיבה

## שרשרת פסיקה בפרק

| פסק דין | ההלכה |
|---|---|
| **בג"ץ 910/86 רסלר נ' שר הביטחון** | הלכה: הפטור מגדיל את הנטל על העותרים, ולכן הם נפגעים במשתמע; הורחבה זכות העמידה והוכר העותר הציבורי, והוצגה ההבחנה בין שפיטות נורמטיבית למוסדית. העתירה נדחתה לגופה. חשיבות למבחן: הרחבת שערי בג"ץ. |
| **קורן נ' שר הביטחון; אמסלם נ' שר הביטחון (2021)** | הלכה: כשיש נפגע ישיר שלא פנה או לא הצטרף, הנטייה לדחות את עתירת העותר הציבורי: "רב על ריב לא לו". חשיבות למבחן: הסייג לעותר הציבורי. |
| **בג"ץ 8684/20 לשכת עורכי הדין נ' שר המשפטים** | הלכה: סובייקטיבי – אין צידוק (הלשכה אף השתתפה בגיבוש); אובייקטיבי – נזק כבד לציבור; שלטון החוק – אין פגם מהותי. העתירה נדחתה על הסף. חשיבות למבחן: שלושת יסודות השיהוי. |
| **בג"ץ 2311/11 סבח נ' הכנסת; בג"ץ חסון נ' הכנסת (חוק יסוד: הלאום)** | הלכה: בסבח הרוב קבע שהעתירה מוקדמת ושאין אינטרס לדון, ונדחתה על הסף. בחסון נקבע שאף אם מוקדמת, יש אינטרס ממשי לדון בשאלה העקרונית, והיא נדונה. חשיבות למבחן: שני שלבי מבחן הבשלות. |
| **כספי (2021–2022); התנועה לאיכות השלטון נ' מבקר המדינה (2024)** | הלכה: בכספי נקבע שיש להצטרף לעתירה הקיימת, אחרת תידחה על הסף. ב-2024 נקבע שהגיעה העת להשתחרר מהלכת כספי כהלכה מחייבת, ולשופט שיקול דעת לכלים אחרים כמו איחוד או הזמנה להצטרף. חשיבות למבחן: עילת סף חדשה וריכוכה. |
| **חוק בתי משפט לעניינים מנהליים, התש"ס–2000 (הוראת חוק)** | תוכן: ס' 5 – עתירה (תוספת ראשונה), ערעור (תוספת שנייה), תובענה (תוספת שלישית); ערעור לעליון בזכות בעתירה ובתובענה וברשות בערעור; ס' 6 – העברה לבג"ץ (חשיבות, רגישות, דחיפות); ס' 9 – צו ביניים. חשיבות למבחן: שאלת הפורום. |
| **סעיפים 15(ג) ו-15(ד) לחוק יסוד: השפיטה (הוראת חוק)** | תוכן: 15(ג) – סעד למען הצדק בעניין שאינו בסמכות ערכאה אחרת; 15(ד) – ביאס קורפוס, מנדמוס לרשויות וגופים הממלאים תפקיד ציבורי, פיקוח על בתי משפט ובתי דין ייחודיים, ובתי דין דתיים בחריגה מסמכות. חשיבות למבחן: סמכות בג"ץ. |

פרק 14

# הבטחה מנהלית, השתק ותוצאות הפגמים — ושיטת פתרון למבחן

## התחייבות הרשות ותוצאות הפגמים

| סוג | מאפיין |
|---|---|
| חוזה רשות | תחולה כפולה – חוזים + משפט מנהלי |
| הסדר מנהלי | מבוסס הסכמת הפרט (הסדר טיעון) |
| הבטחה מנהלית | מפורשת, בידי מוסמך, בכוונה משפטית, ביכולת לקיימה |

✔ **שורה תחתונה — דרישה מקדמית** סמכות – בלי סמכות אין התחייבות (מנבר מול קוגן).

| פסק דין | הלכה |
|---|---|
| רגב | הלכת ההשתחררות |
| קכמן | צידוק לסגת: שוויון |
| עבדאמה | השתק – איזון |
| דישון | סמכות נחזית |
| עזבון שמעון | אנשי עסקים מנוסים ≠ אזרח נבוך |
| רוטברד | פיצוי בלי הכשרה |
| מנצור | השבה מהיום שנודע |

✦ **הגדרה — בטלות יחסית (גיספן)** הבחנה בין פגם לנפקות; הסעד לפי חומרת הפגם, הנסיבות והאינטרס הציבורי. התראת בטלות כסעד גמיש.

| | גישה ישנה | גישה מודרנית |
|---|---|---|
| חוסר סמכות | בטלות מוחלטת (void) | בטלות יחסית |
| טעות בסמכות | נפסדות (voidable) | אותה בחינה לפי נפקות |

| שלב במבחן אמריקאי | מה עושים |
|---|---|
| 1 | ממקמים בשאלה: סמכות / הליך / מהות / סף / ערכאה / תוצאה |
| 2 | חושדים במילים מוחלטות ("תמיד") |
| 3 | מזהים דעת מיעוט, אמרת אגב, הלכה ישנה |
| 4 | בוחרים את התשובה הנכונה והמדויקת ביותר |

★ **טיפ למבחן — לבחינה** זהו התחייבות, בדקו סמכות, השתק או נחזית, והתאימו סעד לפגם.

! **שים לב — מלכודות** הבטחה אינה מחייבת מוחלט; אין להתעלם מצו פגום; אל תבחרו ב"תמיד".

**מילות מפתח:** סאי טקס; ההשתחררות; סמכות נחזית; אזרח נבוך; void / voidable; התראת בטלות; כרופא – אבחנה וטיפול.

## 14.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

## 14.2 שלושה סוגי התחייבויות של הרשות

| סוג | מהותו | דין |
|---|---|---|
| **חוזה רשות** | הרשות מתקשרת בחוזה | **תחולה כפולה** — דיני החוזים ("חוזים יש לקיים") **וגם** המשפט המנהלי (דואליות נורמטיבית, פרק 3); כשהרשות מתקשרת כ"צד רגיל" (קייטרינג לקפיטריה) — דגש על הפרטי; כשהיא מתקשרת כ**קובעת מדיניות** (הסכמי משאבי טבע) — דגש על המנהלי |
| **הסדר מנהלי** | הסדר שמבוסס על הסכמת הפרט, כשהרשות יכלה להחליט גם בלי הסכמתו (הסדר טיעון, הסדר פשרה) | אותם תנאים כמו בהבטחה; וחלה הלכת ההשתחררות |
| **הבטחה מנהלית** | התחייבות **חד-צדדית** של הרשות שלושה (או ארבעה) תנאים — להלן | |

## 14.3 הבטחה מנהלית — התנאים

§ **סעיף — ציטוט / הסעיף** הבטחה של רשות מחייבת רק אם: (1) ניתנה הבטחה מפורשת, ברורה וחד-משמעית — לא הצהרת כוונות כללית; (2) ניתנה בידי בעל הסמכות לתתה, בגדר סמכותו; (3) לנותן הייתה כוונה להקנות לה תוקף משפטי מחייב ; (4) והוא בעל יכולת לקיים אותה.

| פסק הדין | הקביעה |
|---|---|
| **רגב נ' משרד הביטחון** | ניסוח הכלל: לעיתים אפשר להשתחרר מחוזה שלטוני ("הלכת ההשתחררות"), ולהבטחות שלטוניות יש — בתנאים — תוקף משפטי |

| | |
|---|---|
| **סאי טקס קוגן (1997)** | הבטחה מחייבת רק בהתקיים **כל** היסודות: סמכות, כוונה משפטית, יכולת במרד אסירים — לגורם שנתן את ההבטחה (התובע הצבאי) הייתה סמכות לתתה |
| **מנבר (1998)** | לאיש שב"כ **אין סמכות** להבטיח הבטחות לנחקר בעבירות ביטחון — ההבטחה אינה מחייבת |
| **קכמן (אלמנות הטייסים)** | היו שופטים שסברו שלא ניתנה הבטחה בשל העדר סמכות; אחרים — שניתנה, אבל יש **צידוק לסגת** ממנה: השוויון בין משפחות חללי צה"ל |
| **שרוני (2025)** | הבטחה שהייתה כרוכה בהסדר טיעון "התמסמסה" כשההסדר בוטל; המדינה רשאית הייתה לחזור בה מטעמי אינטרס ציבורי |

## 14.4 כשאין סמכות — השתק, סמכות נחזית ופיצויים

| דוקטרינה | תוכן | דוגמה |
|---|---|---|
| **השתק נגד הרשות** | אין לדחות על הסף טענת השתק גם כשהפעולה לא הייתה חוקית — אלא **לאזן** בין האינטרסים | **עבדאמה נ' רשות הפיתוח** (השופטת דורנר) |
| **סמכות נחזית** | כשהאזרח, "הנבוך העומד בפני מסתרי מוסדות השלטון", הסתמך על מי שנחזה כמוסמך | **דישון כפר שיתופי נ' שר החקלאות:** בית המשפט הורה להגדיל מכסות, אף שההבטחה ניתנה בידי מי שלא הוסמך. מנגד — **עזבון שמעון נ' רשות מקרקעי ישראל:** הבטחת שר להקצות קרקעות — לא: "אין מדובר ב'אזרח הנבוך העומד בפני מסתרי מוסדות השלטון', אלא באנשי עסקים ותיקים ומנוסים... שכרו את שירותיהם של עורכי דין בכירים" |
| **בטלות יחסית לגבי העבר** | הפעולה בטלה — אבל התוצאה מותאמת לנסיבות | **מנצור נ' מדינת ישראל:** סגני שרים קיבלו שכר שלא כדין — יחזירו אותו רק מהיום שנודע שאינו כדין |
| **פיצויים בנזיקין** | המעשה הבלתי חוקי אינו מוכשר, אבל הנפגע מפוצה | **רוטברד נ' עיריית בני ברק:** הוועדה המחוזית ביטלה היתר בנייה שניתן שלא כדין; בית המשפט לא הכשיר את ההיתר — אך חייב לפצות את המסתמך על נזקו |

## 14.5 תוצאות הפגמים — מבטלות מוחלטת לבטלות יחסית

| הגישה | תוכן |
|---|---|
| **הישנה** | **בטלות** (void) — תוצאה של **חוסר סמכות**: הפעולה כאילו לא נעשתה מעולם, כלפי כולם. **נפסדות** (voidable) — תוצאה של טעות **בתוך** הסמכות: תקפה עד שבוטלה. (בדקה — כל פגם, בסמכות, בהליך או במהות, נחשב לחריגה מסמכות ומוביל לבטלות.) |
| **הביניים** | שיקול הדעת של בית המשפט בעילות הסף כמסננת (**זילכה נ' ראש עיריית חולון** — עתירה לרישיון למכונות מזל שנדחתה שלא כדין, נדחתה בשל ניקיון כפיים) |
| **היום — בטלות יחסית** | הוצעה בידי **ברק** (שפירא חברה קבלנית) ואומצה (**האגודה לזכויות האזרח נ' שר הפנים**): יש להבחין בין **הפגם** לבין **נפקותו** |

✦ **הגדרה — גיספן (2001), השופט זמיר** גיספן (2001), השופט זמיר: "במקום ההבחנה החדה שבין בטלות... לבין נפסדות... בא לעולם המבחן של בטלות יחסית. לפי מבחן זה יש להבדיל בין הפגם לבין הנפקות .

## 14.6 שיטת פתרון — מבחן אמריקאי במשפט מנהלי

## 14.7 מפת הקורס

| שאלה | הנושא | פרקים |
|---|---|---|
| על מי חל? | גופים ציבוריים, דו-מהותיים | 3 |
| לאן פונים? | בג"ץ / בית משפט לעניינים מנהליים | 13 |
| תנאי סף? | עמידה, שפיטות, מיצוי, שיהוי, בשלות, ניקיון כפיים, עתירה תלויה | 13 |
| סמכות? | חוקיות המנהל; פרשנות; הסדרים ראשוניים; שיורית ועזר; עצמאות שיקול הדעת | 2, 4, 5, 6 |
| הליך? | תשתית עובדתית; שימוע; ניגוד עניינים; הנמקה; היוועצות; פרסום | 7, 8, 9 |
| שיקול דעת? | שיקולים זרים; שוויון; סבירות; מידתיות; משקל ראוי לזכויות | 10, 11, 12 |
| תוצאה? | בטלות יחסית; סעדים; הבטחה, השתק, פיצויים | 14 |

## 14.8 מלכודות נפוצות

**! שים לב — מלכודות נפוצות** לחשוב שכל הבטחה של רשות מחייבת — נדרשים כל התנאים, ויש הלכת השתחררות. לחשוב שהבטחה של מי שאינו מוסמך מחייבת תמיד — רק בחריגים (סמכות נחזית, השתק — באיזון).

## 14.9 שלד לפתרון שאלה — התחייבות הרשות ותוצאות הפגם

## 14.10 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

| הטעות | למה היא שגויה | התיקון |
|---|---|---|
| לחשוב שהבטחה מחייבת תמיד | הרשות רשאית להשתחרר בשל אינטרס ציבורי או שינוי נסיבות | לבחון תנאים והשתחררות |
| להתעלם מחוסר סמכות בהבטחה | מנבר: לאיש שב"כ אין סמכות להבטיח לנחקר | לבדוק סמכות קודם |

| | | |
|---|---|---|
| לראות בכל פגם בטלות מוחלטת להתעלם מצו פגום לבחור תשובות עם "תמיד" או "בכל מקרה" | גיספן: בטלות יחסית – הפגם מול הנפקות עינת הראל: יש לתקוף ישירות ולא להתעלם המשפט המנהלי הוא כלל וחריג | להתאים סעד תקיפה ישירה לחשוד במילים מוחלטות |

## 14.11 תרגיל פתור — הבטחה של פקיד בכיר

## 14.12 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק** שלוש התחייבויות של הרשות: חוזה רשות, הסדר מנהלי, הבטחה מנהלית – כולן דורשות סמכות. תנאי ההבטחה: מפורשת, בידי מוסמך, בכוונה משפטית, ויכולת לקיימה (סאי טקס); מנבר מול קוגן; הלכת ההשתחררות (רגב).

## 14.13 מילון מושגים

## 14.14 נקודות מפתח למבחן

✔ **שורה תחתונה — עיקרי הפרק** חוזה רשות (תחולה כפולה), הסדר מנהלי, הבטחה מנהלית — כולם דורשים סמכות. תנאי ההבטחה: מפורשת וברורה; בעל סמכות; כוונה משפטית; יכולת.

## 14.15 שאלות בסגנון המבחן

## 14.16 שאלות לחשיבה

## שרשרת פסיקה בפרק

| פסק דין | ההלכה |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **הבטחה מנהלית: רגב; סאי טקס; קוגן; מנבר; קכמן (אלמנות הטייסים)** | הלכה: הבטחה מחייבת אם היא מפורשת וברורה, בידי בעל סמכות, בכוונה משפטית וביכולת לקיימה (סאי טקס). בקוגן הייתה סמכות; במנבר לאיש שב"כ אין סמכות להבטיח לנחקר; בקכמן היו שראו צידוק לסגת בשל השוויון בין משפחות החללים; ברגב – הלכת ההשתחררות. חשיבות למבחן: תנאי ההבטחה וההשתחררות. |
| **עבדאמה נ' רשות הפיתוח; דישון נ' שר החקלאות; עזבון שמעון נ' רשות מקרקעי ישראל** | הלכה: בעבדאמה (דורנר) אין לדחות על הסף טענת השתק, ויש לאזן. בדישון סמכות נחזית – הורה להגדיל מכסות. בעזבון שמעון נדחתה הטענה כי מדובר באנשי עסקים מנוסים ומיוצגים ולא באזרח נבוך. חשיבות למבחן: הגנת המסתמך. |
| **רוטברד נ' עיריית בני ברק; מנצור נ' מדינת ישראל גיספן נ' התובע הצבאי הראשי (2001)** | הלכה: ברוטברד המעשה לא הוכשר אך המסתמך זכאי לפיצויים בנזיקין. במנצור יושב השכר רק מהיום שנודע שאינו כדין. חשיבות למבחן: סעדים מותאמים.<br>הלכה: זמיר קבע בטלות יחסית – הבחנה בין הפגם לנפקותו, כרופא שמאבחן ומטפל; חוסר סמכות אינו מוביל בהכרח לבטלות; נבחנים עיוות דין ומניעת ניצול פגמים. חשיבות למבחן: יסוד תורת הבטלות היחסית. |
| **המרכז האקדמי למשפט ועסקים נ' הכנסת (התראת בטלות); עינת הראל נ' מדינת ישראל** | הלכה: במרכז האקדמי החוק לא בוטל, כי התקציב כבר חולק וזהירות מביטול חוק יסוד, אך ניתנה התראת בטלות. בעינת הראל נקבע שהיה צריך לתקוף ישירות ולא להתעלם מהצו. חשיבות למבחן: גמישות הסעד ומחירה. |